

Clase 3

LA FINANCIACIÓN EXTERNA BANCARIA

ÍNDICE

ÍNDICE	1
1. ASPECTOS GENERALES A TODOS LOS CONTRATOS DE FINANCIACIÓN.	5
1.1. LAS COMISIONES Y LOS GASTOS EN LOS CONTRATOS DE FINANCIACIÓN	5
1.1.1. EL CRECIMIENTO DEL PESO DE LAS COMISIONES EN LOS CONTRATOS BANCARIOS	5
1.1.2. LAS COMISIONES VINCULADAS A CONTRATOS BANCARIOS DE FINANCIACIÓN	5
1.2. EL INTERÉS EN LA FINANCIACIÓN BANCARIA	7
1.2.1. EL TIPO DE INTERÉS ORDINARIO	8
1.2.2. EL TIPO DE INTERÉS MORATORIO	8
1.3. LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS EN LOS CONTRATOS BANCARIOS DE FINANCIACIÓN.	9
1.3.1. CONTRATOS CON TIPO DE INTERÉS FIJO	9
1.3.2. CONTRATOS CON TIPO DE INTERÉS VARIABLE	10
1.3.3. LA LIQUIDACIÓN DE LOS INTERESES PACTADOS	11
1.3.4. DÍAS EN QUE HA DE COMPUTARSE LOS AÑOS PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES	11
1.3.5. RESPUESTAS A ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LOS TIPOS DE INTERÉS	12
1.3.6. LAS PERMUTAS SOBRE TIPOS DE INTERÉS (SWAPS)	14
2. EL CONTRATO DE PRÉSTAMO	17
2.1. FINALIDAD ECONÓMICA	17
2.1.1. FINALIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL	17
2.1.2. FINALIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DEL CONSUMO PRIVADO	17
2.2. OBLIGACIONES DEL BANCO Y DEL PRESTATARIO	18
2.2.1. DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL PRÉSTAMO	18
2.2.2. PAGO DE INTERESES Y COMISIONES	19
	1

2.3.	TIPOLOGÍA DE PRÉSTAMOS	19
2.3.1.	PRÉSTAMOS PERSONALES	19
2.3.2.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	19
2.3.3.	PRÉSTAMOS SINDICADOS	21
2.3.3.1.	LA IMPORTANCIA DE LOS PRÉSTAMOS SINDICADOS EN ESPAÑA	21
2.3.3.2.	CONCEPTO	21
2.3.3.3.	CARACTERÍSTICAS	22
2.3.3.4.	OPERATIVA	22
2.3.3.5.	CONTENIDO DEL CONTRATO	23
3.	EL CONTRATO DE LEASING	25
3.1.	CONCEPTO Y FINALIDAD ECONÓMICA	25
3.2.	CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO	25
4.	EL CONTRATO DE LEASING OPERATIVO O RENTING	27
5.	EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	29
5.1.	FUNCIÓN ECONÓMICA	29
5.2.	APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE	29
5.2.1.	FINALIDAD ECONÓMICA	29
5.2.2.	DIFERENCIAS ENTRE LA CUENTA DE CRÉDITO Y EL PRÉSTAMO BANCARIO	30
5.2.3.	EL COSTE REAL DE LAS APERTURAS DE CRÉDITO	31
5.3.	EL CONTRATO DE TARJETAS DE CRÉDITO	32
5.4.	OTRAS MODALIDADES DE APERTURAS DE CRÉDITO	33
5.4.1.	APERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR	34
5.4.2.	CRÉDITO AL PROMOTOR INMOBILIARIO	35
5.4.3.	PÓLIZA DE APERTURA DE CRÉDITO PARA DISPOSICIONES EURIBOR	36
5.4.4.	CRÉDITOS SINDICADOS	36
6.	EL CONTRATO DE DESCUENTO	37
6.1.	CONCEPTO	37
6.2.	FINALIDAD DEL CONTRATO DE DESCUENTO	37
6.3.	CARACTERÍSTICAS	37
6.4.	TÍTULOS DE CRÉDITO OBJETO DE POSIBLE DESCUENTO: LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CERTIFICACIONES, RECIBOS, FACTURAS.	38
6.4.1.	LAS LETRAS DE CAMBIO Y LOS PAGARÉS	38
6.4.2.	LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS PÚBLICOS	38
6.4.3.	LOS RECIBOS NEGOCIABLES	38
6.4.4.	LAS FACTURAS	39

6.5.	EL CÁLCULO DEL COSTE DEL DESCUENTO	40
6.5.1.	TIPO DE INTERÉS	40
6.5.2.	COMISIÓN POR EFECTO	40
6.5.3.	COMISIÓN MÍNIMA POR EFECTO	41
6.5.4.	OTRAS COMISIONES	42
6.5.5.	LA FISCALIDAD DEL DESCUENTO	42
7.	EL CONTRATO <i>FACTORING</i>	44
7.1.	CONCEPTO Y FINALIDAD ECONÓMICA	44
7.2.	TIPOLOGÍA DE <i>FACTORING</i>	44
7.3.	CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO	44
7.4.	OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FACTOR Y DE LA EMPRESA	45
8.	LOS AVALES BANCARIOS	47
8.1.	CONCEPTO	47
8.2.	TIPOLOGÍA DE AVALES	48
8.3.	EL COSTE ECONÓMICO DE LOS AVALES	49
8.4.	LA CONTRAGARANTÍA	49
8.5.	EL VENCIMIENTO DE LOS AVALES	50
9.	EL CONTRATO DE <i>CONFIRMING</i>	51
9.1.	CONCEPTO	51
9.2.	FUNCIONAMIENTO	51
9.3.	VENTAJAS DEL <i>CONFIRMING</i>	52
9.3.1.	VENTAJAS PARA LA EMPRESA PAGADORA	52
9.3.2.	VENTAJAS PARA LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA PAGADORA	53
10.	LAS GARANTÍAS COMO MEDIO DE OBTENER FACILIDADES CREDITICIAS	54
10.1.	LA NECESIDAD DE APORTAR GARANTÍAS	54
10.2.	TIPOLOGÍA DE GARANTÍAS	55
10.2.1.	SEGÚN QUIEN LA PRESTA	55
10.2.2.	SEGÚN EL CONTENIDO DE LA GARANTÍA	55
10.3.	LAS GARANTÍAS PERSONALES: LA FIANZA	56
10.3.1.	CONCEPTO	56
10.3.2.	MODALIDADES DE FIANZA	56
10.4.	LAS GARANTÍAS REALES	57

10.4.1. LA HIPOTECA	57
10.4.2. LA PRENDA	61
10.5. LAS GARANTÍAS ATÍPICAS. LAS DENOMINADAS CARTAS DE <i>COMFORT</i> , CARTAS DE PATROCINIO O <i>COMFORT LETTER</i>	63
10.5.1. CONCEPTO	63
10.5.2. FINALIDAD ECONÓMICA	64
10.5.3. MODALIDADES	64
10.5.4. EFICACIA JURÍDICA	66
10.6. LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA	68
10.6.1. FUNCIONES	68
10.6.2. FUNCIONAMIENTO	69
10.7. LA GARANTÍA DEL ESTADO EN LAS LINEAS DE FINANCIACIÓN ICO COVID	70
10.8. LOS <i>COVENANTS</i> .	72
10.8.1. CONCEPTO	72
10.8.2. TIPOS DE <i>COVENANTS</i>	72
10.8.3. EFICACIA JURÍDICA DE LOS <i>COVENANTS</i>	73
11. LA REESTRUCTURACIÓN Y REFINANCIACIÓN DE LAS DEUDAS EMPRESARIALES Y ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO EN SITUACIONES DE DIFICULTAD	74
11.1. REESTRUCTURACIÓN VS. REFINANCIACIÓN	74
11.2. LAS CALIFICACIONES CONTABLES DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS	74
11.3. LA LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL	75
12. LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS BANCARIOS: LAS PÓLIZAS Y LAS ESCRITURAS PUBLICAS.	76
12.1. FUNCIÓN DE LAS PÓLIZAS	76
12.2. EL ALCANCE JURÍDICO DE LAS PÓLIZAS INTERVENIDAS POR NOTARIOS	76
12.3. LA RECLAMACIÓN JUDICIAL DE LAS PÓLIZAS	76
12.3.1. EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	76
12.3.2. EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL MONITORIO	77
12.3.3. EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DECLARATIVO	77

1. ASPECTOS GENERALES A TODOS LOS CONTRATOS DE FINANCIACIÓN.

1.1. LAS COMISIONES Y LOS GASTOS EN LOS CONTRATOS DE FINANCIACIÓN

1.1.1. EL CRECIMIENTO DEL PESO DE LAS COMISIONES EN LOS CONTRATOS BANCARIOS

La fuerte competitividad que se desató en el sector bancario a partir 1989, iniciada por el Banco de Santander, supuso la ruptura de la calma existente hasta entonces en los mercados crediticios y sirvió para el inicio de una escalada que le ha llevado al primer puesto en el ranking bancario español. No fue más que una estrategia de anticipación al proceso de liberalización del mercado bancario que debía producirse poco después, tras la entrada de España en la CEE. El progresivo efecto en el sector bancario de esta competencia inicialmente supuso un importante encarecimiento de los recursos gestionados de los clientes y una reducción en los intereses cobrados por préstamos y créditos concedidos, sobre todo en los hipotecarios para adquisición de vivienda, es decir lo que se denomina el **margen de intermediación financiera** y que comenzó, desde entonces, a afectar significativamente a esta importante partida de la cuenta de explotación del sector bancario.

Para contrarrestar el perjudicial efecto de este estrechamiento, el sector bancario debió recurrir a potenciar otras fuentes de ingresos de las que hasta entonces se había hecho un tímido uso, como era el cobro de **comisiones** por los servicios prestados por estas entidades. En virtud de ello se fue incrementando de manera generalizada en todas las entidades de crédito las comisiones que se cobran en las operaciones de financiación, así como por cualquier servicio bancario –administración y mantenimiento de cuentas corrientes y de ahorro, gestión de cobro de cheques o recibos, devoluciones de documentos mercantiles de giro, custodia de valores, cajas de alquiler, tarjetas de crédito, etc.-.

1.1.2. LAS COMISIONES VINCULADAS A CONTRATOS BANCARIOS DE FINANCIACIÓN

La concesión de una facilidad crediticia, en cualquiera de sus modalidades –crédito, préstamo, descuento, leasing etc.- comporta en la mayoría de las ocasiones la obligación de satisfacer por parte del cliente unas comisiones a la entidad de crédito, que normalmente se pagan en el momento de la puesta a disposición de dichas facilidades al cliente.

1.1.2.1. LA COMISIÓN DE APERTURA

Esta comisión se suele cobrar en contratos de préstamo, apertura de crédito y leasing. Se calcula sobre el nominal de la operación **y suele oscilar entre un 0,5 y un 4,0 por ciento**, en concepto de gastos de apertura del expediente, aunque bien es cierto que el mismo gasto comporta aperturar un préstamo de diez mil euros, que uno de un millón de euros, variando sustancialmente el importe de la comisión en términos absolutos por este concepto, por lo que simplemente lo convierte en un elemento más de retribución de la operación financiera globalmente. Es por ello que en operaciones de elevado importe (>100.000€) las comisiones suelen ser más próximas al 0,50%, en las de mediano importe (entre 10.000 y 40.000 euros) suelen aproximarse al 2%, siendo las de menor importe las que mayor comisión tienen.

En los préstamos hipotecarios para compra de viviendas esta comisión se devengará de una sola vez y englobará cualesquiera gastos de estudio, de concesión o tramitación del préstamo u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo. Las restantes comisiones y gastos repercutibles a cargo del prestatario, que la entidad aplique sobre estos préstamos, deberán responder a la prestación de un servicio específico distinto de la concesión o de la administración ordinaria del préstamo (Circular 8/90 del Banco de España).

Estas comisiones serán las que en definitiva hayan pactado entre el banco y el cliente y dependerán en mayor medida de la fuerza negociadora de cada una de las partes pudiendo, en según qué casos, no cobrar determinadas comisiones, reducir otras, siempre en función del interés comercial de la operación para la entidad de crédito y de su posición en el pulso negociador. A pesar de ello -según establece el apartado quinto del Capítulo I de la orden de 12-12-1989 y la norma tercera de la Circular 8/90 del Banco de España- en ningún caso la entidad de crédito podrá cargar tipos o cantidades superiores a los contenidos en las tarifas que deben hacer públicas y registrar previamente en el Banco de España.

1.1.2.2. LA COMISIÓN DE ESTUDIO

Se calcula de igual modo sobre el nominal del préstamo y **oscila entre el 0,2 y el 0,5%**, aunque muchas entidades fijan sus máximos en un 2%. Esta comisión se cobra en concepto de gastos derivados del estudio de la operación crediticia. Suele establecerse por las entidades habitualmente un importe mínimo para las comisiones, de modo que si el importe resultante de aplicar el porcentaje de la comisión al nominal del préstamo es inferior al

mínimo se aplicará éste en su lugar. **Este tipo de comisión está prohibido cobrarla actualmente para los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda.**

1.1.2.3. LA COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD

Es frecuente que, en los contratos bancarios de apertura de crédito, sobre todo si este se efectúa en una cuenta corriente, se establezca una comisión -mensual, trimestral, anual, etc.- que se devengará sobre el saldo medio no dispuesto del límite sobre el crédito aperturado y que **suele oscilar entre un 0,25 y un 1,00 %**, según el período liquidado.

EJEMPLO: Una póliza de crédito en cuenta corriente con un límite de 90.000 euros, ha dispuesto de un saldo medio de 60.000 euros, por lo cual le han cobrado los intereses correspondientes pactados en el contrato, pero además se había establecido una comisión sobre el saldo no dispuesto de un 0,50% trimestral, de modo que esta comisión deberá aplicarse a la diferencia entre los 90.000 euros del límite y los 60.000 euros dispuestos, es decir, sobre 30.000 euros, lo que supone una comisión de 1.500 euros trimestrales, resultante de aplicar un 0,50% a los 30.000 euros de saldo medio no dispuesto.

1.1.2.4. LA COMISIÓN DE CANCELACIÓN ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL

Es común establecer una comisión para el supuesto de que el prestatario desee restituir el importe recibido antes de los plazos pactados, para lo cual los contratos ya prevén una comisión que, calculada sobre el nominal pendiente de reembolso y **que suele oscilar del 1,0% al 4,0%** según los casos. No obstante, es habitual que cuando se trata de efectuar una amortización parcial anticipada se exima total o parcialmente de la comisión.

En los supuestos de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda en los que el interés fijado sea variable, esta comisión actualmente no podrá ser superior al 0,50% si la amortización se produce antes de los 5 años de su formalización y del 0,25% si se produce después.

1.2. EL INTERÉS EN LA FINANCIACIÓN BANCARIA

El tipo de interés –como coste financiero para las empresas- se deviene como la razón contractual para las entidades de crédito de los contratos bancarios de financiación, y puede definirse como el precio que se obliga a pagar el prestatario por el disfrute del dinero entregado por el banco durante el tiempo pactado, expresado en un porcentaje en términos anuales.

En los contratos financieros suelen preverse dos tipos de intereses que pueden devengarse a favor de las entidades de crédito, el tipo de interés

ordinario que se produce por el uso de los fondos recibidos por la entidad de crédito, y el interés de demora, devengado por el plazo en que el empresario se constituya como moroso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, bien de restitución del capital, bien de los intereses.

1.2.1. EL TIPO DE INTERÉS ORDINARIO

Desde la libertad de fijación de tipos de interés por parte de las Entidades de Crédito en las operaciones que concierten con sus clientes -Orden de 3 de marzo de 1987- sólo la fuerza negociadora de las partes será el elemento determinante en la función definitiva de los tipos de interés en los contratos. A pesar de ello debemos tener presente que un interés abusivo por parte del Banco podría violar la Ley Azcárate o Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura, que establece la nulidad de todo contrato de préstamo o equivalente *“en el que se estipule un interés notablemente, superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulta aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”*.

Hasta la actualidad ha tenido una aplicación muy excepcional la Ley Azcárate, dentro de un marco de libertad absoluta en la fijación de tipos de interés entre las partes contratantes, siendo abrumadora la corriente jurisprudencias -menor- que consideran válidos en derecho intereses que sobrepasen el 20%.

Es frecuente también que los tribunales de justicia, en aplicación de la normativa sobre protección de consumidores y usuarios puedan declarar como abusiva alguna cláusula determinante del tipo de interés en algunos contratos de financiación, como sucedió recientemente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 con la declaración de nula de la cláusula sobre el tipo de interés en los contratos de Tarjeta de crédito revolving que no habían sido negociadas y en las que se establezca una indemnización de los daños y perjuicios desproporcional.

En los casos en que se declare nula la cláusula que determine el tipo de interés, como si por alguna razón no se determinara el tipo de intereses ordinario en el contrato, ello impide que la entidad de crédito pueda posteriormente reclamar interés alguno considerando en primer lugar su carácter accesorio y en segundo lugar que según el Código de Comercio los préstamos no devengarán interés si no se hubiere pactado por escrito. Así que el prestatario solo deberá cumplir con la devolución del principal prestado, sin tener que abonar ninguna cantidad en concepto de intereses.

1.2.2. EL TIPO DE INTERÉS MORATORIO

Es unánime en las entidades de crédito establecer en los contratos unos intereses denominados “moratorios” y que se devenguen desde el día siguiente del vencimiento de las obligaciones de reembolso del principal capital e intereses, es decir, de las obligaciones dinerarias del deudor, siendo válido la capitalización de los intereses a los efectos de la liquidación de intereses de demora al amparo del artículo 317 del Código de Comercio.

El porcentaje de interés aplicado por las entidades de crédito para los plazos de demora en el caso de no consumidores suele oscilar entre un veinticinco y un treinta por ciento, reduciéndose este aun veinte o veinticinco por ciento para los supuestos de préstamos hipotecarios. Sobre este punto, en la actualidad, sí que sería conveniente hacer una reflexión sobre la posibilidad de censurar como usurero unos tipos de intereses moratorias del 29 o 30%, considerando que el tipo de mercado del interés ordinario -o retributivo- se sitúa en la actualidad en 8 o 9 por ciento, hasta 10 o 12 puntos menos que los habidos hace diez años, habiéndose quedado por tanto muy por encima del tipo de interés de mercado en la actualidad. A pesar de ello **los intereses moratorios pactados suponen una cláusula penal moderable por los Tribunales de justicia**. Su falta de determinación en el contrato no permitirá a la entidad de crédito reclamar más que el interés legal del dinero desde el día en que el deudor incurra en mora.

Los intereses moratorios que se pretendan cobrar en operaciones de **consumidores** están topados según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (2015) en **2% porcentuales adicionales a los tipos ordinarios**, tanto en los préstamos personales, como en los préstamos hipotecarios. Los intereses moratorios que se hubieran fijado por encima de este umbral del 2% se considerarán abusivos y la jurisprudencia ha establecido que en estos casos se deberá cobrar el tipo de interés ordinario fijado para la operación de financiación.

1.3. LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS EN LOS CONTRATOS BANCARIOS DE FINANCIACIÓN.

Las entidades de crédito tienen previsto diversos modelos de contratos donde las cláusulas relativas a la determinación del tipo de interés varían según la modalidad negociada entre la entidad y el cliente. Los intereses deberán ser pactados entre las partes y pueden ofrecer múltiples variedades.

1.3.1. CONTRATOS CON TIPO DE INTERÉS FIJO

Son aquellos contratos en los que las partes pactan un tipo de interés fijo para toda la vida del contrato sin posibilidad de modificarse sin el consentimiento de ambas partes. Esta modalidad de tipo de interés es la que se utilizaba en contratos de corta duración, tras un largo período de tipos bajos de interés, está resultando muy recomendable cerrar tipos fijos incluso para períodos largos, como sucede en los préstamos hipotecarios de largo plazo.

1.3.2. CONTRATOS CON TIPO DE INTERÉS VARIABLE

Los contratos con tipos de interés variable son aquellos en los que las partes pactan un tipo de interés para un primer período estableciendo que para los sucesivos períodos el tipo de interés se determinará adicionando o sustrayendo un diferencial a un tipo de referencia determinado, diferencial que mayor será cuando menos poder negociador tenga el deudor y menor cuando mayor poder negociador tenga. Hemos de tener presente que el rating de la empresa será un elemento que condicionará a la entidad financiera el tipo mínimo que podrá negociar.

El tipo de referencia no podrá ser nunca el de la propia entidad acreedora, dado que ello supondría dejar el contrato al arbitrio de una de las partes contratantes y con ello se vulneraría claramente lo dispuesto en el artículo 1.256 del Código civil. Por ello en el contrato se deberá fijar como referencia algún indicador del mercado monetario, como puede ser cualquiera de los siguientes:

a) **EURIBOR -Euro Interbank Offered Rate-** Es decir, el del mercado interbancario del euro a un plazo determinado, normalmente a tres, seis o doce meses- utilizado para todo tipo de operaciones de crédito o préstamo, sea cual fuere su destino.

c) **IRMH -Índices de referencia del Mercado Hipotecario-**. Es el tipo de referencia oficial publicado mensualmente en el Boletín Oficial del Estado mediante resolución del Banco de España y utilizado en los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas por particulares, compuesto a su vez por diferentes índices:

c.1) El tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre conjunto de entidades de crédito, siendo cada uno un índice diferente (IRPH). Este índice ha sido muy controvertido, ante la

declaración por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2020 la posibilidad de anular la cláusula por la que se fije este tipo de interés si se considera que es abusiva. Las entidades de crédito españolas hace ya varios años que dejaron de utilizar este índice de referencia en sus préstamos hipotecarios, pero aún son muchos los que continúan teniéndola en vigor.

c.2) El tipo interbancario a un año (EURIBOR). Es el índice más utilizado en los préstamos hipotecarios, tanto de viviendas como para empresas en la financiación de la compra de locales comerciales o naves industriales.

d) Tipo de interés legal del dinero. Publicado anualmente por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente, fijado actualmente en el 3%. (No se utiliza como una referencia activa)

La modalidad de determinación del tipo de interés dependerá por tanto en la mayoría de las ocasiones de la duración de la operación como ya hemos apuntado anteriormente. Ante los actuales bajos tipos de interés son muchos los prestatarios que están optando por cerrar un tipo fijo para toda la duración del préstamo, aunque sea a largos plazos. Sin embargo, dado que los tipos de interés fijos a largos plazos tienen una equivalencia superior a un 2% sobre el Euribor anual a las grandes empresas no les interesa acogerse a ellos y optan por referenciar sus tipos de interés al Euribor.

1.3.3. LA LIQUIDACIÓN DE LOS INTERESES PACTADOS

Una vez determinado por el contrato el tipo de interés aplicable a un período concreto ha de concretarse igualmente el momento en que debe de liquidarse los intereses correspondientes. La práctica bancaria ha puesto de manifiesto que estos intereses pueden liquidarse, bien en los mismos momentos en que deba de reembolsarse el principal, o bien en momentos diferentes, como pueda ser los primeros días de cada trimestre natural, pudiendo negociarse si éstos se liquidarán por anticipado o bien por vencido, siendo el coste real de la financiación más cara si se liquidan anticipadamente.

1.3.4. DÍAS EN QUE HA DE COMPUTARSE LOS AÑOS PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES

El Código de Comercio, en su artículo 60, establece que *“en todos los cálculos de días, meses y años, se entenderán: el día, de 24 horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano, y el año de 365 días. Exceptuándose las letras de cambio, los pagarés y los préstamos, respecto de los cuales se estará a lo que especialmente para ellos establece este código -o su legislación específica-”*. A pesar de esta última indicación ni el Código de Comercio ni ninguna otra legislación hace referencia alguna al cómputo en los contratos de préstamo.

Ello nos permitiría llegar con facilidad a la conclusión de que en cualquier operación de financiación, excepto el préstamo, se debería de aplicar una fórmula financiera en la que en el cómputo de días se estableciese 365, pero pesar de ello ha sido, y es práctica usual de la banca, calcular los intereses de las operaciones de financiación computando como base 360 días y no 365, con lo cual, al menos en las operaciones que no sean préstamos parece que estamos ante una aparente contradicción y que los tribunales, salvo en sentencias muy aisladas han considerado válida dicha práctica por tratarse de un uso bancario.

1.3.5. RESPUESTAS A ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LOS TIPOS DE INTERÉS

1.3.5.1. ¿QUÉ ES EL T.A.E., Y QUÉ FINALIDAD TIENE?

Es la Tasa anual equivalente, es decir, el tipo de interés, en términos anuales que se obtiene implícitamente en las operaciones de activo o de pasivo, que junto al tipo de interés se devengan comisiones, como medio para que el cliente pueda apreciar el coste real de las mismas -en operaciones de activa- o la rentabilidad -en operaciones pasivas-.

Para su cálculo deberemos seguir la fórmula indicada en el anexo V de la Circular 8/90 del Banco de España:

La equivalencia financiera a que se refiere el apartado 2 de la NORMA OCTAVA de esta Circular tiene la siguiente expresión matemática.

$$\sum_{n=1}^n D_n (1 + i_k)^{-t_n} = \sum_{m=1}^m R_m (1 + i_k)^{-t_m}$$

Siendo:

D = Disposiciones.

R = Pagos por amortización, intereses u otros gastos incluidos en el coste o rendimiento efectivo de la operación.

n = Número de entregas.

m = Número de los pagos simbolizados por R.

t_n = Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la de la disposición n.

t_m = Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la del pago m.

i_k = Tanto por uno efectivo referido al período de tiempo elegido para expresar los t_n y t_m en números enteros.

Por su parte, el tipo anual equivalente i (TAE) a que se refiere la indicada NORMA OCTAVA:

$$i = (1 + i_k)^k - 1$$

La razón de su existencia no es otra que permitir a los clientes de las entidades de Crédito comparar el coste efectivo de las operaciones bancarias, ante la disparidad de costes que tienen las mismas y que hace muy difícil, en ocasiones, saber el coste real que conllevará cada una y cual entre dos opciones es la más rentable para el cliente.

Imaginemos un particular que desea solicitar un préstamo en un banco de 12.000 euros a devolver en dos años. Cada una de las entidades se lo ofrece del siguiente modo:

OFERTA BANCARIA		
CONCEPTO	ENTIDAD A	ENTIDAD B
Comisión de apertura:	1,5%	1,0%
Comisión de estudio	0,2%	0,2%
Interés deudor	12,0%	12,5%
Devolución del capital	mensual	trimestral
Intereses	mensuales anticipados	trimestrales vencidos

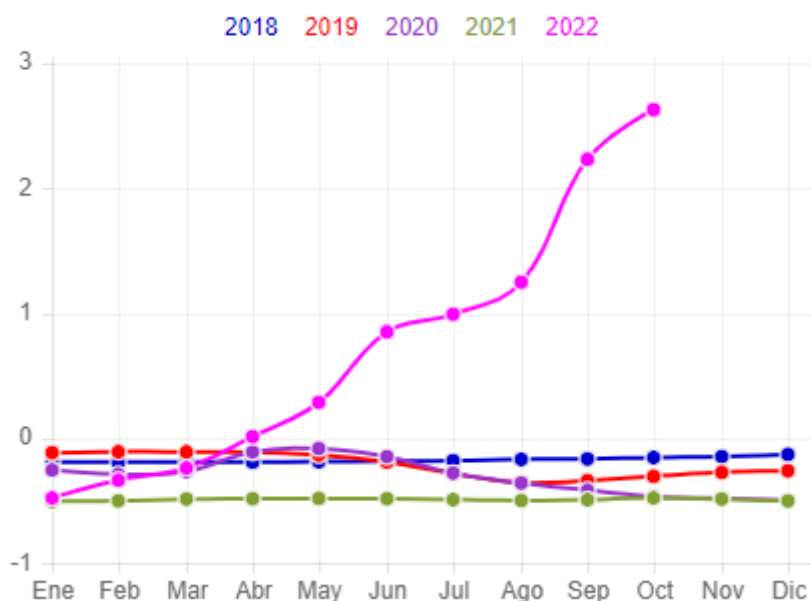
Las condiciones ofrecidas por la entidad A tendrían una TAE del 15,06%, las ofrecidas por la entidad B tendrían una TAE del 14,61%, por lo que la oferta más barata para el cliente será la ofrecida por el Banco B.

1.3.5.2. ¿DE QUE DEPENDEN LA EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS?

Tras la ya comentada liberalización de los tipos de interés en los contratos bancarios parece que sólo el resultado de la oferta y la demanda debiera ser la que determinase el interés del mercado de dinero, pero esto no es así. Ello se debe a la facultad que, antes el Banco de España, y actualmente el Eurosistema, tiene conferida, y que le permite operar en los mercados de dinero inyectando o detrayendo dinero al sistema, movilizándolo recursos de las entidades bancarias variando sus coeficientes de caja, certificados, etc. Todo ello pone de manifiesto que esta institución tiene la facultad de provocar alteraciones de precios del dinero en el mercado con el fin de controlar los efectos inflacionistas o de debilidad de nuestra divisa en los mercados internacionales.

Una clara muestra de ello recientemente es la importante subida llevada a cabo en los tipos de intervención en los mercados por parte del Banco Central Europeo a lo largo de 2022 a raíz de la significativa escalada de la inflación a cifras no vistas en Europa desde hace muchas décadas y motivado por el encarecimiento de las materias primas por causa de la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia.

Gráfico de evolución del Euribor Mensual:



Fuente: www.euribordiarario.es

1.3.6. LAS PERMUTAS SOBRE TIPOS DE INTERÉS (SWAPS)

1.3.6.1. FINALIDAD ECONÓMICA

Las empresas que tienen operaciones de financiación concertadas a largos plazos pueden asegurar un tipo de interés determinado a través de la contratación de un Swap, por la cual en el mercado de tipos de interés¹ se concierta durante un cierto período de tiempo los flujos de ingresos/pagos de dos instrumentos financieros basados en un mismo importe nominal.

Los swaps, aunque pueden utilizarse con finalidad meramente especulativa, se utilizan normalmente para **evitar el riesgo asociado a la concesión de un crédito a la suscripción de títulos de renta fija o al cambio de divisas**. Suponen en sí misma una operación de permuta de obligaciones financieras sin alterar las obligaciones contractuales de los activos o instrumentos que contienen las obligaciones que se truecan.

Aunque inicialmente estos instrumentos fueron utilizados por las autoridades monetarias y por los gobiernos para minimizar los riesgos especulativos, hoy en día es utilizada con la intermediación de los bancos, por multitud de empresas para reducir los riesgos por la volatilidad de los tipos de interés.

Este producto financiero fue comercializado masivamente por las entidades de crédito entre los años 2006 a 2008, para cubrir los préstamos hipotecarios de particulares y financiaciones a largo plazo de empresas ante las eventuales y probables subidas de tipos de interés en sus financiaciones referenciadas. Su comercialización generaba considerables beneficios a las entidades de crédito. Pero tras el estallido de la crisis financiera a partir de 2008 y la progresiva caída de los tipos de interés, hizo que estas empresas que habían fijado tipos de interés entre el 4 y el 6% vieran como sus tipos de referencia caían en picado y se encontraban pagando unos tipos mucho más altos que otras empresas que no habían contratado estos swaps. Al desear deshacer estas operaciones se dieron cuenta que el precio de liquidarlas en el mercado tenía un coste altísimo que derivó en numerosas reclamaciones ante las entidades de crédito por considerar que no habían sido suficientemente informados de los riesgos que entrañaban su contratación. Los tribunales de justicia han ido con el tiempo dando la razón a las empresas y condenando a las entidades de crédito por vicio en el

¹ Los mercados de negociación de los swaps no son mercados organizados oficiales, este hecho hace que el contrato finalmente acordado sea más útil, flexible y ajustado para las necesidades iniciales que se perseguían con el acuerdo por cada una de las partes

consentimiento, al considerar que las pequeñas empresas no eran conscientes realmente de la complejidad del producto contratado ni de los riesgos que contraían.

En la actualidad ha dejado de comercializarse por parte de las entidades de crédito los swaps entre las pequeñas y medianas empresas, especialmente en un momento histórico de tipos de interés muy bajos y sin riesgos de subidas de tipos, donde incluso los tipos fijos contratados son sumamente atractivos, y se han reservado de nuevo a empresas de gran tamaño e inversores institucionales.

1.3.6.2. TIPOS DE SWAPS

Los swaps en las operaciones de financiación pueden contratarse de formas diferentes atendiendo a diferentes criterios:

1. **Por su vinculación con el contrato subyacente:** Pueden clasificarse en **swaps implícitos**, en los que se contratan simultáneamente al contrato financiero subyacente y se incorpora en el mismo contrato de financiación, determinando un tipo fijo que no genera liquidaciones paralelas al contrato original, o bien **swaps explícitos**, en los que la operación se contrata de forma separada al contrato subyacente, y puede ser simultánea o posterior al mismo, generando liquidaciones diferenciadas del contrato original. Mientras el tipo de interés esté por debajo del swap generará liquidaciones negativas y por tanto una obligación de pago para la empresa y si es tipo de interés supera al del swap generará liquidaciones a favor de la empresa.
2. **Por su forma de activación:** En los swaps explícitos y que se contratan sin ligarse a un subyacente concreto pueden optarse por diferentes fórmulas de contratación, como por ejemplo, que tengan un **swaps tipo fijo** determinado o los **swaps de techo/suelo** que se activen a favor o en contra en función de que los tipos de interés de mercado bajen por debajo de un determinado límite *-floor-* (liquidaciones contrarias) o suban por encima de determinado límite *-caps-* (liquidaciones a favor).

2. EL CONTRATO DE PRÉSTAMO

2.1. FINALIDAD ECONÓMICA

El contrato de préstamo bancario, desde el punto de vista jurídico, es un contrato real, unilateral y formal, por el que el banco entrega una suma de dinero determinado a una persona física o jurídica (prestatario) obligándose ésta, a restituir otro tanto en el plazo convenido, incluidos los intereses y comisiones correspondientes. Ningún sector doctrinal ni fuente legal establece una finalidad concreta para el dinero recibido, ahora bien, el prestatario recibe el importe en su totalidad en el momento inicial, comenzando en ese momento el devengo de intereses. Ello, desde el punto de vista de rentabilidad de las inversiones, no es prudente si no se destina a una finalidad concreta que permita obtener una rentabilidad superior al coste financiero del préstamo recibido.

2.1.1. FINALIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

En la práctica los préstamos se deben utilizar para una finalidad concreta. Si se trata de una empresa (bien se trate de un autónomo o de una sociedad) irá normalmente ligada a la financiación de una inversión productiva, es decir, el pago por la adquisición de una máquina, un vehículo o una edificación en el caso de préstamos a largo plazo, o de un pago a proveedores, financiación de una importación o el pago de unos impuestos, en el caso de préstamos a corto plazo.

Las entidades financieras suelen exigir la acreditación del destino de la inversión y el importe a financiar puede ser del 100% del total de la inversión (sin los impuestos directos como el IVA) para las inversiones de pequeño importe o cuyo plazo de amortización no exceda del medio plazo (4 o 5 años) y del 60% o 70% en el caso de financiar bienes inmuebles, en el que los plazos de devolución son más a largo plazo (entre los 8 y los 15 años).

2.1.2. FINALIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DEL CONSUMO PRIVADO

En el supuesto de consumidores los préstamos suelen tener por finalidad también la financiación de adquisición de bienes duraderos y de consumo y los plazos de financiación suelen ser de 2 a 5 años en el caso de mobiliario, electrodomésticos y otros bienes de consumo similares. Se extiende entre los 4 e incluso hasta los 10 años para la adquisición de vehículos nuevos y podría alcanzar los 30 o 40 años inclusive en el caso de la adquisición de viviendas.

En el caso de los préstamos al consumo no siempre la entidad de crédito exige una acreditación específica del destino de la inversión. Por eso es frecuente que muchos bancos ofrezcan a través de sus páginas webs y aplicaciones móviles ofertas personalizadas a sus clientes (previos estudios de sus ratings) fijándoles un importe de préstamo solo con hacer un clic en su móvil u ordenador y sin necesidad de justificar el destino del préstamo.

2.2. OBLIGACIONES DEL BANCO Y DEL PRESTATARIO

El contenido obligacional del contrato recae, fundamentalmente, sobre el prestatario, cuya obligación principal es la restitución de la suma de dinero obtenidas en préstamo, así como el pago de intereses, añadiéndose otras obligaciones, por imposición del clausurado de la póliza de préstamo, que giran en torno a la principal.

2.2.1. DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL PRÉSTAMO

CALCULO DE CUOTA DE PRÉSTAMO SEGÚN SISTEMA FRANCÉS

$$\frac{CP \times (i / k) \times (1 + i / k)^{a \times k}}{(1 + i / k)^{a \times k} - 1}$$

donde:
 CP = Capital prestado
 i = tipo de interés nominal (no expresado en %)
 k = número de cuotas anuales (12 si es mensual, 4 si es trimestral, etc)
 a = número de años del préstamo (1,5 si es año y medio)

El prestatario se obliga a devolver en el plazo pactado el importe del préstamo. No necesariamente debe realizarse de una sola vez, sino que puede determinarse que la devolución del nominal se realizará mediante amortizaciones periódicas -mensual, trimestral, semestral o anual- que pueden ser iguales, crecientes o decrecientes, siendo la primera la más corriente en los préstamos para financiar la compra de bienes duraderos, en los cuales se establece una cuota constante comprensiva de capital e intereses siguiendo el sistema francés que se calcula según la fórmula indicada en la página siguiente. No obstante, la generalidad de los contratos suelen establecerse con pagos mensuales en el caso de préstamos al consumo y también mensuales o trimestrales en el caso de las empresas.

No obstante, también pueden concertarse préstamos que se amortizan en su totalidad a vencimiento (con intereses anticipados o también a vencimiento). Este tipo de amortizaciones se establecen normalmente para préstamos a corto plazo (de duración inferior a un año)

Podría también establecerse una combinación de préstamos en los que un porcentaje (normalmente entre el 70% y el 80%) pagaderos mediante un sistema de amortización francés y el resto pagadero a vencimiento (*bullet*). Esta opción es más propia de un proceso de refinanciación en el que la empresa ha demostrado dificultades para hacer frente a sus pagos y se presenta como una solución para reducir temporalmente su carga financiera por devolución de préstamos.

2.2.2. PAGO DE INTERESES Y COMISIONES

Como es fácil de suponer, el motivo fundamental de un contrato de préstamo bancario reside en el pago de intereses y las comisiones como beneficio que obtiene la entidad de crédito en contraprestación a la entrega de dinero. Los intereses podrán pactarse que serán liquidados mensual, trimestral o por otra periodicidad cualquiera y con carácter anticipado o vencido. En el primer supuesto, es decir, en el caso de que éstos se liquiden por anticipado, el efecto que ello produce sobre el tipo de interés aplicado es de un encarecimiento real de la operación y que debe ponerse de manifiesto de una forma clara en el cálculo de la Tasa Anual Equivalente de la operación.

En los contratos de préstamo se acostumbra a establecer una comisión de apertura, que puede alcanzar hasta un 4,0% sobre el nominal prestado y una comisión de estudio que puede alcanzar hasta un 0,5% de dicho nominal, incidiendo en la rentabilidad total de la operación a medida que el plazo de la operación es más corto, como ya se expuso en el [apartado 1.1.2](#) de este módulo.

2.3. TIPOLOGÍA DE PRÉSTAMOS

2.3.1. PRÉSTAMOS PERSONALES

Son aquellos préstamos donde el riesgo de la concesión del mismo, por parte de la entidad financiera, descansa exclusivamente en la solvencia personal del prestatario o garantes personales en su caso y suele responder a operaciones con vencimientos no superiores a 10 años en el caso de consumidores, y de 5 años en el caso de empresas. Tienen también destino la adquisición de un bien concreto. Cuando estos préstamos están destinados a financiar la adquisición de bienes de consumo por particulares se les denomina **préstamos al consumo**.

2.3.2. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Los préstamos con garantía hipotecaria son aquellos en que la garantía de la devolución del principal e intereses del mismo se garantiza con una hipoteca sobre un bien generalmente inmueble.

Los préstamos hipotecarios más frecuentes son aquellos **destinados a la adquisición de viviendas, locales comerciales o naves industriales**, y su duración varía dependiendo de la finalidad, dado que mientras para naves industriales y locales comerciales (utilizados normalmente por empresas) la banca no suele realizar préstamos que superen los 10 años (extensible a 15 años en algunos casos), para adquisición de vivienda se puede llegar hasta 25 o 30 años en algunos casos. Aunque en algunos casos hay entidades que financian hasta los 40 años, como ya indicábamos anteriormente.

A pesar de ello y dada la importante garantía que esta modalidad de operaciones supone para las entidades financieras es frecuente que los particulares o las empresas acudan al préstamo hipotecario para financiar la adquisición de bienes distintos al inmueble hipotecado, o para realizar inversiones en proyectos empresariales o industriales o para cualquier otro destino que pueda ser de interés -refinanciación de deudas-, considerando el beneficio que supone la los largos plazos de amortización que se pueden conseguir con este tipo de financiación.

Este tipo de operaciones se dividen, según la instrumentalización, en préstamos con reembolso de una sola vez, y préstamos a amortizar por cuotas periódicas.

La modalidad de préstamos más frecuentes son los denominados **préstamos de cuota constante e interés variable**, es decir, aquellos en los que la cuota periódica, que se compone de capital e intereses, es siempre la misma, aunque en las fechas establecidas de revisión del tipo de interés éste varíe, de modo que no afecta a la cuota periódica, sino a la duración del préstamo. De este modo si los tipos de interés han subido el vencimiento del préstamo se extenderá en el tiempo hasta su total amortización, y si éstos disminuyen disminuirá de igual manera. Esta modalidad está prevista para los préstamos para adquisición de vivienda a largo plazo con garantía hipotecaria como un medio de garantizar al prestatario que ocurra lo que ocurra en los mercados financieros no se verá perjudicado con una variación no prevista de su cuota del préstamo.

La formalización de estos préstamos requiere normalmente de la intervención de otros profesionales tendentes a concluir la operación, como son los tasadores del inmueble a hipotecar, el notario que intervendrá el acto, la gestoría que tramitará la liquidación de impuestos y la inscripción de

las escrituras en el Registro de la Propiedad. La designación de estos profesionales se debe realizar de mutuo acuerdo, no pudiendo ser impuesta por la entidad de crédito, aunque la práctica habitual hace que sean estas entidades quien designan a los profesionales intervinientes.

2.3.3. PRÉSTAMOS SINDICADOS

2.3.3.1. LA IMPORTANCIA DE LOS PRÉSTAMOS SINDICADOS EN ESPAÑA

El elevado importe que en ocasiones puede suponer una financiación a una gran empresa o un organismo o administración pública -superiores a ocho o diez millones de euros normalmente- no es generalmente por una única entidad financiera, bien por carecer de capacidad económica para ello o bien por el importante riesgo tal volumen supondría y que una única entidad financiera no debería asumir en solitario.

Esta modalidad de contratación apareció en España a finales de los años setenta, de la mano principalmente de bancos extranjeros que tenían interés en actuar en nuestro mercado. Tras un declive en su uso a mediados de los 80 volvió de nuevo a finales de esa misma década a cobrar una importante significación, para volver a decaer de nuevo en la crisis económica de principios de los 90.

Se puede con ello deducir que la proliferación de esta modalidad de financiación se produce en épocas de prosperidad económica, donde los excedentes de tesorería empresarial ponen al sector industrial en la cabeza negociadora frente a la banca, necesitada de negocio inversor para rentabilizar sus recursos. Contrariamente, en momentos de crisis económica, las importantes necesidades de financiación del sector empresarial y la cauta y prudente política crediticia de la banca sitúa a ésta de nuevo en la cabeza negociadora y por tanto ajustar sus inversiones según sus criterios.

La actividad de los préstamos sindicados ha sido significativa mientras la actividad bancaria ha estado muy atomizada entre muchas entidades de crédito. Tras la crisis financiera del 2008 en España y el proceso de concentración de entidades su número se ha reducido considerablemente, reservándose su importe a operaciones muy significativas. Banco Santander,

BBVA y BNP son las tres entidades que lideran en España los préstamos sindicados².

2.3.3.2. CONCEPTO

Los préstamos sindicados son contratos por los cuales varias entidades de crédito entregan al prestatario (o se obliga a poner a disposición del acreditado en el supuesto de un crédito) fondos hasta el límite y por el plazo estipulado, obligándose el acreditado a su vez al reembolso de los mismos y al pago de los intereses y comisiones pactados en el contrato.

Normalmente es este tipo de préstamos existe una entidad que asegura la operación, es decir, que si transcurrido el plazo pactado con el cliente, deberá de ser ella la que asuma el riesgo de la operación hasta su límite total si no encontró otras entidades de crédito a las que hacer participar de la operación suscribiendo parte del crédito sindicado.

2.3.3.3. CARACTERÍSTICAS

Entre las características típicas de los préstamos sindicados podemos destacar las siguientes:

- a) Se reserva para **operaciones de elevada cuantía** de la que normalmente precisan grandes empresas o administraciones públicas. Estaríamos hablando de operaciones que superen los 10 o 15 millones de euros.
- b) La operación de préstamo es **liderada por una entidad** financiera, denominada jefe de fila o **Banco manager**, que es aquella a la que se dirige el cliente a plantear la operación que asegura al prestatario la totalidad del importe solicitado.
- c) Durante un plazo determinado la entidad aseguradora ofrece los derechos de suscripción de la titularidad activa del préstamo a otras entidades financieras.
- d) Cada una de las entidades participantes, aseguradoras y colaboradoras se constituyen en acreedores directos del prestatario por las cantidades facilitadas (o puestas a su disposición en un crédito).

² Diario El Confidencial. 28/04/2022. Santander, BBVA y BNP lideran los préstamos sindicados con la caída de CaixaBank

e) Los fondos se canalizan siempre a través de una sola entidad que será una de las que haya liderado la operación.

f) Se trata de una relación comercial atípica en nuestro ordenamiento jurídico.

2.3.3.4. OPERATIVA

La tramitación de un préstamo sindicado desde su inicio se realiza siguiendo los siguientes pasos:

1º) El cliente acude a una entidad de crédito para solicitar un préstamo o crédito sindicado y que esta entidad diseñe la operación de acuerdo con las necesidades financieras de éste, dando entrada a en la operación a otras entidades de crédito.

2º) El **Banco Manager** elabora un documento “*Placing Memorandum*” en el que se detalla la operación y se facilita la información técnica, económica y financiera suficiente para que las entidades interesadas puedan realizar un ordenado estudio de la misma. En dicho documento se manifiesta que los datos aportados han sido facilitados por el propio cliente.

3º) El Banco Manager invita a otras entidades de crédito a participar en la operación.

4º) Una vez determinadas las entidades que participaran en la operación se suscribe el contrato de préstamo/crédito sindicado oportuno, aunque es posible que la operación sea suscrita en su integridad por el Banco Manager y después realice la sindicación de la operación, con el importante riesgo que puede suponer el desinterés del resto de entidades para sumarse como socios en la misma.

5º) Durante la vida de la operación es posible la adhesión de nuevas entidades de crédito si así se ha previsto el contrato, cediendo una entidad de crédito total o parcialmente su posición acreedora con todos sus riesgos, acciones y derechos, incluso los de defensa legal.

2.3.3.5. CONTENIDO DEL CONTRATO

El contrato genera obligaciones, tanto para las entidades de crédito sindicadas como para el prestatario:

a) Obligaciones de las entidades de crédito sindicadas: Su única obligación es la entrega de los fondos o puesta a disposición de los mismos a favor del acreditado, siendo responsabilidad exclusiva de cada entidad cumplir con su obligación, no estableciéndose ninguna responsabilidad subsidiaria para el resto de las entidades o el banco agente.

b) Obligaciones para el acreditado o prestatario: El prestatario deberá pagar las comisiones de agencia, apertura y disponibilidad, no siendo obligada su publicación por parte de las entidades de crédito por ser un supuesto excluido de las obligaciones dimanadas de la Circular 8/90 del Banco de España, así como los intereses que devengue la operación y reembolsar al vencimiento de los fondos dispuestos o recibidos.

3. EL CONTRATO DE LEASING

3.1. CONCEPTO Y FINALIDAD ECONÓMICA

El contrato de leasing es un contrato en virtud del cual un profesional o un empresario puede obtener una financiación a través de un medio flexible y nuevo de disponer de un bien de equipo alquilándolo en, vez de comprarlo. Esta operación es realizada por todas las entidades de crédito, así como por las, denominadas “entidades de leasing”, que forman parte de las entidades de financiación estudiadas en los apuntes de la Clase 1, creadas la mayoría de ellas por Bancos y Cajas de Ahorro en su origen, tramitándose estas operaciones como un producto más de inversión a través de sus redes de oficinas.

A través de estas operaciones las citadas entidades compran el material siguiendo las instrucciones del futuro usuario, alquilándoselo durante un plazo convenido y mediando la percepción de un canon fijado en el contrato y que debe reservar al arrendatario una opción de compra sobre el material al término del período inicial. De este modo se persigue un doble objetivo, la empresa accede a una interesante financiación a la hora de adquirir un bien de equipo, con importantes deducciones fiscales y la entidad financiera asegura el capital entregado mediante la propiedad del bien arrendado.

Su origen viene del inglés “*to lease*”, que significa alquilar, dado que fue en Estados Unidos donde surgió esta figura a finales del siglo pasado. En España apareció hacia los años 60, y no ha sido hasta 1977 cuando ha surgido la primera regulación sobre este tema, aunque hasta ahora, su única regulación se centra en aspectos fiscales y contables, pero no contractuales.

A través de este modelo de contrato las empresas pueden acceder a la financiación de bienes de equipo como maquinaria, equipos electrónicos o informáticos o vehículos industriales. También se utiliza frecuentemente para la financiación de inmuebles para uso comercial o industrial.

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Del contrato de arrendamiento financiero o leasing Podemos destacar las siguientes características:

- 1. El arrendatario deberá ser un empresario o profesional.** La Ley no permite que se adquieran mediante contratos de arrendamiento financiero bienes para el uso personal, por lo que se exige que el usuario sea un empresario o un profesional.

2. Los bienes objeto de leasing deben estar afectos a una actividad industrial, comercial, profesional, agrícola, ganadera, artesanal o forestal. Puede tratarse de bienes muebles, de uso comercial o industrial, como maquinaria, barcos y aviones, vehículos industriales y comerciales, equipos médicos, fotocopiadoras y mobiliario de oficina, equipos informativos, etc. Puede ser también bienes inmuebles, como edificios, locales comerciales, naves industriales, oficinas y despachos profesionales, fábricas, inmuebles aún por construir, etc. Se trata en definitiva que se trate de bienes perfectamente **identificables**. Por tanto, no lo pueden ser objeto de financiación mediante leasing una inversión en instalaciones o bienes consumibles. Tampoco podría financiarse la inversión en un fondo de comercio, el know how o la propiedad industrial o intelectual.

3. El procedimiento a seguir en la contratación de un leasing difiere del seguido en otros contratos de financiación: El usuario elige el bien objeto de leasing, solicita a una entidad de leasing el estudio y otorgamiento de la operación. Una vez autorizado se firma el contrato, comprando la sociedad de leasing el bien al proveedor designado por el arrendatario y haciéndole entrega a ésta del mismo, comenzando el mismo día de la suscripción del contrato el pago de las cuotas de arrendamiento.

4. El contrato deberá tener una duración mínima. La duración del contrato de Leasing es el período que media entre la firma del contrato y el momento pactado para la finalización del período de cesión de uso. Dos aspectos son considerados para establecer la extensión del período bajo el Contrato: la presunta vida útil del bien y la tasa de amortización fiscal, no obstante, la Ley del Impuesto de sociedades determina unos plazos mínimos para estos contratos que son de dos años para bienes muebles y de 10 años para bienes inmuebles. La legislación no establece sin embargo una duración máxima. No obstante, las entidades financieras no suelen conceder plazos de financiación mediante leasing por plazos superiores a 5 años en el caso de los bienes muebles y de 12 o 15 años en el caso de los bienes inmuebles.

5. El arrendatario tiene una opción de compra al finalizar el contrato. Al finalizar el período de vigencia el arrendatario podrá optar por devolver el bien arrendado o bien adquirirlo en propiedad definitivamente, pagando el precio de la opción de compra, cuyo importe queda determinado en el momento de la formalización del contrato. Lógicamente la inmensa mayoría de las veces el usuario

opta por quedárselo en propiedad, dado que el valor de la opción de compra es insignificante en comparación a su valor de mercado y suele corresponder a una cuota más de alquiler y además no lleva carga financiera por intereses.

6. El arrendamiento financiero tiene ventajas fiscales. En los últimos años el contrato de arrendamiento financiero ha perdido buena parte de la fiscalidad favorable que había tenido en sus orígenes. No obstante, en todos los casos los intereses de las cuotas de arrendamiento son deducibles en el impuesto de sociedades. La parte correspondiente a la amortización de capital no tiene una imputación directa en el impuesto. Como regla general las empresas deberán imputar en el impuesto un importe correspondiente al doble de la amortización del inmovilizado financiado según las tablas de amortización fiscalmente aceptadas. Sin embargo, si se trata de empresas de reducida dimensión o profesionales este importe será del triple. Lo que supone una aceleración en el proceso de amortización y por tanto con efectos importantes en el diferimiento del impuesto.

4. EL CONTRATO DE LEASING OPERATIVO O RENTING

El leasing operativo o renting -según Fernández Inglés- es un «*contrato mercantil en virtud del cual el arrendador, siguiendo instrucciones expresas del arrendatario, compra en nombre propio determinados bienes muebles con el fin de, como propietario, alquilárselos al arrendatario para que éste los utilice por un tiempo determinado, pudiendo éstos ser sustituidos o ampliados durante el período contractual*».

Este concepto que nos podría inducir a considerar que el renting es similar al leasing debemos ampliarlo señalando las siguientes características diferenciadoras:

- a) **El usuario busca un verdadero arrendamiento**, no estando interesado normalmente en la adquisición de la propiedad del bien cedido al final del contrato.
- b) **No se establece generalmente una opción de compra** al término del mismo, no obstante, de fijarse ha de ser equivalente al valor del bien en el momento de la transmisión.
- c) El coste del arrendamiento incorpora normalmente el **valor de depreciación del bien**, la **carga financiera**, el

seguro de avería o pérdida del bien cedido y el **mantenimiento** del mismo, que puede ser realizado por el arrendador o una empresa subcontratada para ello.

d) Las empresas arrendadoras pueden ser empresas especializadas o los propios proveedores del bien cedido en arrendamiento, en cualquier caso, no están sujetas a la disciplina del Banco de España como sucede con las sociedades de arrendamiento financiero.

e) **Las empresas arrendatarias no deben reflejar el endeudamiento** derivado de estos contratos en sus estados financieros, contrariamente como sucede en el leasing.

f) **El importe de la cuota de arrendamiento es deducible** completamente del impuesto de sociedades, siempre que el bien esté afecto a la actividad empresarial / profesional. En el caso del IRPF sólo puede reducirse en el caso de que esté afecto al 100% a la actividad empresarial / profesional.

Debido a sus numerosas ventajas, el renting se ha convertido en un medio de financiación para el uso de vehículos y equipos informáticos y electrónicos fundamentalmente debido a sus rápidas obsolescencias y ventajas que ofrece la externalización de los procesos de mantenimiento de los mismos.

5. EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO

5.1. FUNCIÓN ECONÓMICA

Muchas veces, tanto los comerciantes como quienes no lo son, saben que van a necesitar dinero, pero no cuándo o cuánto necesitarán. La obtención de un préstamo en estas condiciones es desventajosa para ellos, pues si se calcula con exceso, el prestatario estará obligado a abonar unos intereses que no tendrían justificación. Para eludir estos inconvenientes, las personas necesitadas de crédito acuden a los Bancos y en vez de concertar un préstamo, conciertan una apertura de crédito. El cliente tendrá crédito para disponer del dinero que necesite o para disponer de otros medios de pago en la cuantía y en el momento en que los necesite, dentro de unos límites convenidos de previamente.

En definitiva, mediante la apertura de crédito, el cliente obtiene la ayuda económica del Banco como ocurre en el préstamo. Pero es una ayuda que, a diferencia de este otro contrato, se adapta elásticamente a las exigencias del momento, salvando las desventajas antes apuntadas de la rigidez del préstamo. Y si esta operación de crédito se instrumenta en forma de cuenta corriente, como es costumbre, el cliente obtendrá una ventaja: poder aminorar su deuda frente al Banco haciendo ingresos en la cuenta cuando sus medios de tesorería se lo permitan, evitando así el pago innecesario de intereses.

En virtud de todo ello podríamos definir la apertura de crédito como aquel contrato por el que el Banco se obliga dentro del límite pactado y mediante una comisión que percibe del cliente, a poner a disposición del mismo, y a medida de sus requerimientos, sumas de dinero o a realizar otras prestaciones que le permitan obtenerlo al cliente.

5.2. APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE

5.2.1. FINALIDAD ECONÓMICA

Es habitual que los contratos de apertura de crédito se realicen bajo el soporte operativo de una cuenta corriente, de modo que el acreditado puede hacer cargos y abonos en la cuenta, domiciliar recibos, expedir cheques contra la cuenta, hasta un límite previamente fijado. Se trataría en definitiva de una cuenta corriente donde **se pacta un límite para disponer en descubierto** a un tipo de interés pactado y hasta un límite determinado. Podría pactarse incluso para los saldos superiores a cero (acreedores) el pago de intereses por parte del banco y a favor del cliente en contextos con tipos

de interés positivos (no como sucede en los momentos actuales en que los tipos de referencia son negativos).

Respecto a la aplicación de intereses han de efectuarse conforme a los saldos diarios, que se anotan según disposiciones y reintegros, aunque la operación de liquidación se realice en plazos más amplios: tres, seis, nueve meses, etc.

En el contrato podría pactarse reducciones parciales al límite, atendiendo a un calendario prefijado de modo que a medida que se cumplen las fechas fijadas el límite queda reducido a una cantidad determinada. Como ocurriría si se concediese una apertura de crédito en cuenta corriente por 60.000 euros con rebajas del límite de 15.000 euros trimestrales de modo que el límite a los tres meses pasaría a ser de 45.000 euros, a los seis meses de 30.000 euros, a los nueve meses de 15.000 euros y a los doce meses se debería reintegrar cualquier saldo deudor dispuesto hasta dejar la cuenta con saldo 0 o acreedor.

5.2.2.DIFERENCIAS ENTRE LA CUENTA DE CRÉDITO Y EL PRÉSTAMO BANCARIO

DIFERENCIAS

a) **Entrega / Puesta a disposición:** En el préstamo el Banco, entrega al prestatario el importe señalado en el contrato, abonándolo en su cuenta ordinaria, mientras en la apertura de crédito el Banco no entrega nada, sino que se compromete a entregar hasta un límite fijado, con arreglo a los actos de disposición del cliente. Será éste quien, cuando lo desee, disponga hasta un límite señalado en la póliza, total o parcialmente, en la medida de sus necesidades, procediendo el Banco a cargar dichas cantidades en la cuenta del crédito.

b) **Amortización / Reducción:** En el préstamo la deuda del cliente con el Banco se reduce únicamente en el momento de las amortizaciones, mediante la devolución parcial de la cantidad prestada. La devolución total de ésta supondrá la cancelación del préstamo. Sin embargo, en la apertura de crédito el cliente puede reducir su deuda con el Banco mediante ingresos en la cuenta de crédito, independientemente de la reducción del límite del crédito en las amortizaciones, de tal forma que puede llegar a convertirse en acreedor del Banco, sin que por ello quede cancelado el crédito.

SEMEJANZAS

- a) No es preciso que se extiendan en póliza.
- b) Las pólizas han de ir intervenidas por fedatario público (notario) si se quiere conservar la fuerza ejecutiva contra los acreditados.

5.2.3. EL COSTE REAL DE LAS APERTURAS DE CRÉDITO

El gran número de comisiones que conlleva una apertura de crédito hace necesario valorar la incidencia que cada una de ellas tiene en la globalidad del coste de la misma. En primer lugar, la existencia de comisiones de apertura y estudio en la apertura calculadas sobre el límite concedido provoca que contra menor saldo medio necesitemos del límite pactado, más costoso será el efecto de las comisiones sobre dicho saldo medio. Por ejemplo: Sobre un límite de 60.000 euros, con unas comisiones globales de un 1,5 % (900 euros), si la media de disposición ha sido de 30.000 euros la incidencia de la comisión (900€) sobre el importe realmente financiado (30.000) es de un 3 % ($900 * 100 / 30.000$). Similar importancia tiene la denominada comisión sobre el saldo medio no dispuesto, esta comisión, que se calcula sobre el saldo medio que no ha sido dispuesto del total del límite de la apertura, calculado día a día y que provoca un encarecimiento en términos relativos del saldo medio dispuesto.

Para estudiar con mayor profundidad y desde un punto de vista práctico el cálculo de los costes de las cuentas de crédito vamos a desarrollar un ejemplo en el que se deberá obtener la liquidación final del primer período de liquidación de un contrato teniendo en consideración los siguientes datos:

- | | |
|--|---|
| a) Límite del contrato: 60.000 euros. | g) Periodicidad de la liquidación: Trimestral |
| b) Tipo de interés acreedor: 1,0% | h) Saldo medio acreedor: 9.000 euros. |
| c) Tipo de interés deudor: 5,0% | i) Número de días con saldo acreedor: 20 |
| d) Tipo de interés para saldos excedidos: 29,0% | j) Saldo medio deudor: 42.000 euros. |
| e) Comisión sobre máximo saldo excedido: 2,0% | k) Saldo medio no dispuesto: 18.000 euros. |
| f) Comisión sobre saldo medio no dispuesto: 0,5% | |

1) Cálculo de los intereses acreedores:

$$\frac{\text{Saldo medio acreedor} \times \text{Tipo de interés acreedor} \times \text{Número de días con saldo acreedor}}{36.500}$$

$$(9.000 \times 1,00 \times 20) / 36.500 = 4,93 \text{ euros.}$$

2) Cálculo de los intereses deudores:

$$\frac{\text{Saldo medio deudor} \times \text{Tipo de interés deudor} \times \text{Número de días con saldo deudor}}{36.000}$$

$$(42.000 \times 5,00 \times 70) / 36.000 = 408,33 \text{ euros.}$$

5) Cálculo de la comisión sobre saldo medio no dispuesto

$$\text{Saldo medio no dispuesto} \times \text{Comisión sobre saldo medio no dispuesto}$$

$$18.000 \times 0,5 = 90 \text{ euros.}$$

6) Cálculo del resultante de la liquidación del trimestre:

* Intereses acreedores:	+ 4,93
* Intereses deudores:	- 408,33
* Comisión saldo medio no dispuesto:	- 90,00
* Resultante liquidación:	- 493,40 €

Si se considera además que la formalización del crédito conllevó las siguientes concisiones:

- a) Comisión de apertura: 1,1 % (660 euros)
- b) Comisión de estudio: 0,5% (300 euros)

Ello supone que las comisiones totales pagadas sobre el límite suman 960 euros y su incidencia sobre un trimestre supondría una cuarta parte, es decir, 240 euros (960 / 4), por lo que el coste real del crédito durante el trimestre liquidado ha sido de 493,40 + 240 = 733,40 euros.

5.3. EL CONTRATO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Una forma muy común de obtener financiación a corto plazo mediante un límite de crédito es mediante el uso de tarjetas de crédito. El uso de estas tarjetas por parte de empresas y autónomos está limitado al pago de adquisiciones de bienes y servicios, aunque su uso más común es el de pago de gastos corrientes de empresa por parte de directivos y trabajadores de las empresas (gastos de viaje -aviones, trenes, trasportes públicos, etc.-, comidas de trabajo, gasolina, materiales de papelería y otros

aprovisionamientos de pequeño importe). A través del uso de las tarjetas de crédito las empresas tienen un mejor y más detallado control de los pagos realizados de sus empleados con fondos de la empresa.

El crédito viene determinado por el límite fijado por la entidad de crédito a la empresa que viene determinado por un límite total para todo el conjunto de las tarjetas de crédito y uno individual por tarjeta emitida. Las entidades de crédito facilitan después la información del uso de estas tarjetas de una forma útil para su control y procesos de contabilización de los movimientos

La modalidad de tarjeta de crédito más utilizado por las empresas son aquellas que tienen un vencimiento mensual del importe dispuesto, recuperando la disponibilidad del límite una vez satisfecho el pago del saldo dispuesto durante el mes anterior, aunque cabe la posibilidad de que se incorpore la opción de pago aplazado de modo que el saldo dispuesto de la tarjeta de vaya pagando periódicamente, bien con un porcentaje determinado del límite mensual de la tarjeta, un porcentaje del crédito dispuesto, o bien un importe fijo mensual.

En los contratos de tarjeta de crédito de empresa intervienen por tanto tres sujetos, de un lado la entidad de crédito, de otro la empresa como titular del crédito y responsable de la obligación de pago de los importes dispuestos, y por último el beneficiario de la tarjeta, que será el directivo o empleado que hace uso de ella para realizar pagos por cuenta de la empresa.

El uso indebido de la tarjeta de crédito o el impago de los saldos dispuestos a su vencimiento autoriza a la entidad de crédito a cancelar anticipadamente el saldo total adeudado de la tarjeta de crédito y a exigírselo a la empresa titular.

La **contraprestación** de este contrato viene determinada por dos fuentes de ingresos para la entidad de crédito. De un lado por las comisiones cobradas por la emisión o renovación anual de la tarjeta de crédito, y en el caso de que tenga aplazados los pagos de los saldos dispuestos tendrá adicionalmente un tipo de interés que suele ser elevado comparativamente a otras fórmulas financieras de financiación. Por otro lado, la entidad de crédito percibe también una comisión de la entidad de crédito cobradora donde se ha hecho uso de la misma en pago de compras de bienes o servicios en establecimientos adheridos a sus sistemas de pago.

5.4. OTRAS MODALIDADES DE APERTURAS DE CRÉDITO

La apertura de crédito por parte de las empresas puede deberse a múltiples necesidades de financiación, que en función de su destino se pueden

clasificar en las siguientes modalidades contractuales, todas ellas de práctica habitual en todas las entidades financieras.

5.4.1. APERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

La actividad de comercio exterior de las empresas que importan o exportan requieren de líneas específicas de financiación. Las aperturas de crédito son por tanto aquellos contratos por los cuales el Banco concede a sus clientes un crédito hasta un límite máximo determinado con la finalidad de que éstos lo destinen exclusivamente a la financiación de operaciones de exportación o importación que habitualmente se realizarán a través del mismo Banco y que estarán, condicionadas a la presentación de la documentación que recaiga sobre la operación comercial financiada.

A través de la **financiación de exportaciones** las entidades de crédito anticipan el cobro de ventas efectuadas a clientes extranjeros hasta que se produce el reembolso de las facturas anticipadas por el cobro de las mismas por parte de la entidad financiadora. En el supuesto de la **financiación de importaciones** la entidad realiza el pago a un proveedor de una factura comercial y el banco otorga un préstamo que financia dicho pago por un plazo que previamente se haya pactado (60, 90, 120 días), a cuyo vencimiento, la empresa financiada deberá devolver los importes financiados.

Son características comunes a las aperturas de crédito para la financiación de operaciones de comercio exterior:

1. La concesión de un crédito hasta un límite determinado utilizable por disposiciones parciales.
2. Las disposiciones del crédito están condicionadas a la presentación de la documentación que el banco exija. Cabe la posibilidad en la financiación de exportaciones de que el banco se niegue a facilitar la disposición correspondiente a una operación en que no tenga claro la solvencia del importador extranjero para hacer frente al pago del producto exportado por el cliente, reserva que suele quedar latente en el clausurado del contrato de crédito existente entre el banco y el exportador.
3. El importe del crédito debe destinarse a la financiación de operaciones de exportación / importación.

4. El cobro de las importaciones se realiza habitualmente por el banco que financia la operación.

En el supuesto de crédito para la financiación de exportaciones, las operaciones de exportación se realizan habitualmente por la entidad que concede el crédito, es decir, que el cobro del importe de la factura de exportación debería ser domiciliada en la cuenta que el exportador tenga abierta en el banco que le ha concedido el crédito. A pesar de ello, en ocasiones no se produce así, bien porque la necesidad de financiación nace con posterioridad a la domiciliación del cobro y ésta se realiza en una entidad distinta, bien porque, el importe de la exportación es tan importante que un Banco sólo no desea anticiparla completamente, de modo que la misma factura se anticipa parcialmente en más de un banco, pero sólo uno recibirá el reembolso del importe.

Dentro de las líneas de crédito para financiación del comercio exterior es muy importante también los límites de **créditos documentarios**. Los créditos documentarios han nacido para dar seguridad al tráfico comercial internacional, de forma que las empresas exportadoras puedan realizar ventas de sus productos en otros mercados extranjeros teniendo la seguridad de cobro de la venta realizada. También tienen utilidad para garantizar ante un determinado pedido que requiere de un proceso de fabricación costoso, que sí se cumple con las condiciones del pedido en calidad y plazos de entrega tiene asegurado el cobro de la misma. Para la empresa importadora también genera la seguridad de que su banco pagará la compra del producto o productos importados si la mercancía solicitada llega a su destino.

La operativa de los créditos documentarios requiere de la intervención como mínimo de dos bancos, el de la empresa exportadora y el de la empresa importadora. El banco del importador envía un mensaje cifrado a través de Swift al banco del exportador por el cual garantizar el pago de la importación siempre que se cumpla las condiciones de calidades, documentación acreditativa de la misma solicitada y plazos de entrega exigidos por el importador. Es una forma de avalar el pago si se cumplen las condiciones fijadas. Para ello tiene que existir una relación de confianza y de crédito abierto entre las dos entidades intervinientes. En el caso de que no existiera esta relación deberá intervenir algún otro banco, generalmente más grande e internacional, que pueda intermediar entre ambos contraguarantizando el crédito documentario. Sin la existencia de los créditos documentarios difícilmente habría sido posible la expansión del comercio mundial en las cifras en las que se mueven actualmente.

5.4.2. CRÉDITO AL PROMOTOR INMOBILIARIO

El crédito al promotor inmobiliario es una modalidad consistente en la concesión de un límite al promotor de una obra -civil o industrial-, bajo la garantía hipotecaria del acreditado por la que, el Banco, a medida que se le entregan certificaciones de las fases de la obra acabada deja disponer del límite por el importe certificado. Esta modalidad tiene la peculiaridad de no comenzar las amortizaciones del capital hasta que la obra está acabada y se ha dispuesto de la totalidad del límite, a pesar de ello con la periodicidad que se hubiere establecido se deberán satisfacer los intereses del mismo.

5.4.3. PÓLIZA DE APERTURA DE CRÉDITO PARA DISPOSICIONES EURIBOR

No es extraño que las grandes compañías que dispongan de aperturas de créditos en Bancos a través de las cuales se les permite realizar disposiciones en forma de préstamos a un vencimiento determinado (una semana, un mes, tres meses, etc.) tomada directamente por el banco en el mercado interbancario (EURIBOR) para el cliente, al precio cerrado en dicho mercado más un diferencial pactado con el cliente y que será el beneficio del banco. Este modelo de contratos requiere normalmente disposiciones no inferiores a 150.000 euros, y las superiores en múltiplos de 30.000 euros y se les suele facilitar a clientes de elevado Rating de solvencia dada la escasa rentabilidad de las operaciones realizadas bajo esta modalidad y el elevado importe de las mismas.

En muchas ocasiones esta modalidad de financiación se complementa con una póliza de crédito en cuenta corriente estableciéndose un límite conjunto para ambas y disminuyendo uno a medida que asciende el otro.

5.4.4. CRÉDITOS SINDICADOS

De igual modo que se ha expuesto al estudiar el préstamo, los créditos pueden ser del mismo modo que los préstamos sindicados entre varias entidades financieras siguiendo esta modalidad contractual una operativa muy similar a la allí analizada, con la diferencia de que en el crédito las entidades participantes se comprometen a poner a disposición del acreditado los fondos pactados, no existiendo la entrega inicial característica de los préstamos.

6. EL CONTRATO DE DESCUENTO

6.1. CONCEPTO

Es el contrato celebrado entre la entidad de crédito y su cliente, por el cual el primero adquiere créditos, no vencidos, del segundo, salvo buen fin, abonándole, anticipadamente su importe nominal, deducidos los intereses y comisiones que se hubieran pactado.

6.2. FINALIDAD DEL CONTRATO DE DESCUENTO

En el marco de la actividad económica de las empresas es habitual que las ventas de bienes o servicios se realicen mediante cobros aplazados, que suelen oscilar entre 30 y 180 días, siendo el plazo más común 90 días. La razón básica de que se produzcan estos aplazamientos radica en su extremo radial, los puntos de venta a los particulares, que, dada su pequeña dimensión necesitan ser financiados hasta que consiguen vender los productos que han adquirido de sus proveedores, función que suelen realizar las estos últimos. Esta circunstancia hace que sus proveedores (distribuidores mayoristas o productores) se encuentren necesitados de financiar de algún modo el desfase existente entre el cobro de sus clientes y sus pagos, muchos de los cuales son al contado (nóminas, suministros de luz, agua, gas,) y por ello recurren a la venta de sus derechos de crédito sobre clientes, para adquirir, de este modo la liquidez necesaria que le permitirá hacer frente a sus pagos.

6.3. CARACTERÍSTICAS

Son características comunes a todos los contratos de descuento que:

- a) Es un contrato celebrado entre el banco y su cliente (generalmente un empresario).
- b) El banco adquiere títulos de crédito no vencidos del cliente.
- c) La cesión de títulos al banco se realiza salvo buen fin. Una cesión salvo buen fin significa que si llegado el vencimiento y presentado el documento de crédito cedido por el cliente al librado del mismo, éste no satisface su importe y es devuelto, el cedente deberá reembolsar su importe, el cual suele estar penalizado con comisiones que oscilan entre el 4 y el 5 por ciento del valor del nominal.

d) El banco abona en el momento del descuento el importe nominal del documento de crédito, deduciendo los intereses y, en su caso las comisiones pactadas.

e) El descuento se realiza al amparo de un contrato de crédito para descuento, con un límite pactado con la entidad financiera como si de un crédito para descuento de efectos se tratase.

6.4. TÍTULOS DE CRÉDITO OBJETO DE POSIBLE DESCUENTO: LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CERTIFICACIONES, RECIBOS, FACTURAS.

6.4.1. LAS LETRAS DE CAMBIO Y LOS PAGARÉS

El descuento de las letras de cambio se realiza mediante la figura del endoso, por virtud del cual el acreedor cambiario pone a otro acreedor cambiario en su lugar dentro de la letra de cambio, con carácter pleno y limitado. Es importante hacer resaltar que, aunque se habla de endoso, los efectos son los mismos cuando el Banco aparece en el anverso de la cambial como tomador de la letra, al ser el librador de la misma quien se la cede. No hay, por tanto, necesidad de que el librador se la gire a su propia orden para luego endosársela al Banco. Esta modalidad de descuento es la más utilizada en el tráfico bancario.

6.4.2. LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS PÚBLICOS

Por su frecuencia conviene hacer referencia al descuento de obras que representan un crédito contra la Administración y a favor del contratista. La Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos de las Administraciones Públicas establece -Art. 200.- que, la Administración deberá pagar a aquellas personas físicas o jurídicas que hubieran contratado con la ella dentro de los treinta días siguientes a las fechas de expedición de las certificaciones correspondan a la obra ejecutada. A pesar de ello estos plazos no se cumplen generalmente lo que obliga a muchos empresarios a ceder el derecho de cobro pendiente al banco, conforme prevé la propia Ley para anticipar su importe, siendo necesario para ello la notificación fehaciente a la Administración del acuerdo de cesión (art. 201). A partir de ese momento la Administración realizará el mandamiento de pago a favor del banco.

6.4.3. LOS RECIBOS NEGOCIABLES

Los recibos -como dice García-Pita y Lastes- son documentos muy frecuentes en el tráfico económico que tienden a representar el derecho de crédito dinerario que un comerciante ostenta frente a su cliente, adoptando

una estructura muy similar a la de la letra de cambio o del cheque, en el sentido de que contiene un mandato de pago dirigido por su emitente al deudor, en favor de un tercer sujeto nominativamente designado. En virtud de esta característica se le denominan “recibos negociables”, dado que nominalmente representan el futuro justificante de pago de una deuda, y al igual que las facturas pueden ser utilizados como documentos mercantiles justificativos de un crédito contra un tercero y por tanto, objeto de cesión en descuento debido a la ventaja que conlleva su función de giro.

6.4.4. LAS FACTURAS

La práctica bancaria, y con ella la aparición de bases de datos que recogen las aceptaciones de documentos bancarios que no han sido pagados (R.A.I.), unida al mejor control administrativo que supone emitir por el propio deudor el documento de pago ha supuesto que en numerosas empresas dejaran de aceptar giros contra sus cuentas corrientes y ha preferido sustituir esta modalidad de pago por la transferencia o remisión de cheque al vencimiento de la factura. Todo ello ha supuesto una dificultad para el acreedor de escasa solvencia financiera que ha visto como el tradicional descuento de letras o recibos para financiar su empresa ha dejado de ser posible ante situaciones de esta naturaleza.

A pesar de ello el acreedor dispone aún de un instrumento útil para movilizar el crédito que tiene pendiente de cobro y obtener a cambio de él una financiación necesaria, ello será posible a través del descuento de la factura.

Para obtener las mayores garantías jurídicas en la cesión, y por tanto recomendable cuando la cuantía a ceder sea significativa, es recomendable que la cesión sea intervenida por un fedatario público -corredor de comercio o notario- y notificada por el mismo conducto al deudor, no siendo oponible frente a terceros si es realizado de otro modo.

RIESGOS QUE ENTRAÑA PARA EL BANCO EL DESCUENTO DE FACTURAS

- * Al no tener en ningún momento la conformidad de la factura esta podría no corresponder a un crédito real -presunta estafa-.
- * El Banco está expuesto a que le pueda ser opuesto todas las excepciones de carácter personal que el deudor tuviera frente al cedente.

* Si no se ha realizado la cesión en documento público y notificada fehacientemente, al deudor se podría sufrir un embargo del crédito que el cliente ostenta con el deudor por parte de otro acreedor.

Todo ello hace conveniente que junto con la cesión de un crédito se pudiera obtener la conformidad del deudor, o por lo menos ceder junto a la factura otros documentos mercantiles que pudieran demostrar con mayor certeza la real existencia del mismo (pedido de la mercancía, albarán de entrega, etc.), sobre todo por si el cliente se deviene insolvente y la entidad financiera tiene que reclamar el importe exclusivamente al deudor a través de un procedimiento declarativo, para lo cual deberá tener suficientes pruebas de la existencia del mismo, no bastando por tanto para ello documentos que no sean originales.

6.5. EL CÁLCULO DEL COSTE DEL DESCUENTO

El descuento de letras de cambio, pagarés o recibos tiene unos costes financieros para el descontante y que podrían resumirse en los siguientes:

6.5.1. TIPO DE INTERÉS

Se calcula nominalmente desde el día del descuento hasta el día del vencimiento y en función del número de días existente entre ambas fechas

Ejemplo: El interés que deberá pagarse por el descuento de un pagaré de 6.000 euros. de nominal, descontado el día 10 de marzo, con vencimiento 15 de mayo a un tipo de interés del 5,50 % será de 60,5 euros:

$$\frac{6.000 \text{ (nominal)} \times 5,50 \text{ (tipo de interés)} \times 66 \text{ (días)}}{36.000} = 60,50\text{€}$$

6.5.2. COMISIÓN POR EFECTO

Es frecuente que el descuento incorpore una comisión por cada efecto cedido y que consiste en una comisión sobre el nominal que varía en función de las siguientes circunstancias:

- a) Si es un documento aceptado (letra de cambio o pagaré) y domiciliado (en una cuenta bancaria) puede costar aproximadamente entre un 3 y un 5 por mil.
- b) Si es un documento no aceptado y domiciliado suele oscilar entre un 7 y un 10 por mil.

- c) Si es un documento no domiciliado puede costar entre un 8 y un 15 por mil.

Las comisiones reflejadas suelen ser máximas pudiéndose negociar otras inferiores o ninguna, según la posición negociadora de la empresa. En cualquier caso, si se establecen comisiones el tipo de interés que se establece para el descuento puede variar según si el vencimiento es a un mes, dos meses, tres meses, o más estableciéndose tramos de interés para cada uno de los vencimientos.

En numerosas ocasiones se suele establecer también un mínimo de comisión global por efecto para el supuesto de que el importe conjunto entre la comisión y el interés a cobrar no llegue a esta cifra.

Ejemplo. - Calcular el coste del descuento de dos efectos, uno de 6.000 de euros, con vencimiento 15 de mayo, aceptado y domiciliado y otro de 90 euros no domiciliado con vencimiento 15 de abril, descontados ambos el 1 de marzo bajo las siguientes condiciones:

Tipos de interés: Hasta 90 días: 5,00%, hasta 60 días 5,50%, hasta 30 días 6,25%, más de 90 días 10,75%.

Comisiones: Aceptados y domiciliados: 0,4%, no aceptados y domiciliados: 0,8%, no domiciliados: 1,0%.

Mínimo global por efecto: 6 euros.

a) Efecto de 6.000 euros:

- 1) $(6.000 \times 6,25 \times 75) / 36.000 = 78,125$ euros por el interés.
- 2) $6.000 \times 0,4 / 100 = 24$ euros por la comisión.
- 3) $78,125 + 24 = 102,125$ euros total.

b) Efecto de 90 euros:

- 1) $(90 \times 5,50 \times 46) / 36.000 = 0,63$ euros por el interés.
- 2) $90 \times 1,0 / 100 = 0,90$ euros
(por ser la suma del interés y la comisión inferior a 6 euros se aplica el mínimo de 6 euros).
- 3) $0,63 + 0,90 = 1,53$ euros, por tanto se cobrará 6,00 euros.

En muchas ocasiones la comisión por efecto se negocia excluirla y a cambio se pacta un tipo de interés fijo sea cual fuere el vencimiento del efecto.

6.5.3. COMISIÓN MÍNIMA POR EFECTO

En numerosas ocasiones se negocia un importe mínimo fijo por efecto descontado, que pretende cubrir como mínimo los costes operativos del descuento. Este mínimo sólo tiene incidencia en aquellos supuestos en que el interés cobrado por un efecto es inferior a las cifras que la entidad tiene definidas para cada documento como mínimo, bien por tratarse de un efecto

de nominal muy pequeño o por descontarse por muy pocos días no existiendo comisión por efecto o siendo ésta muy pequeña.

Ejemplo: Se descuenta un efecto el día 1 de marzo, con vencimiento 18 de marzo, de nominal 360 euros con una comisión del 0,4% por ser aceptado y domiciliado y una comisión mínima por efecto de 1,80 euros y a un tipo de interés del 6,00%. Se establece una comisión global por efecto de 5 euros:

- 1) $(360 \times 6,00 \times 17) / 36.000 = 1,02$ euros.
- 2) $360 \times 0,4 = 1,44$ euros (por ser inferior a 1,80 euros se aplica una comisión de 1,80 euros)
- 3) Coste total = $1,02 + 1,80 = 2,82$ euros.
- 4) Por ser el coste total (2,82 euros) inferior a 5 euros se cobrará el mínimo global de 5 euros.

6.5.4. OTRAS COMISIONES

Pueden existir otros costes adicionales al descuento, como por ejemplo la comisión de no truncamiento, para el supuesto de que se desee que el documento descontado llegue al destinatario físicamente. También puede existir otra comisión de no truncamiento en devolución para cuando se desee que el documento devuelto por impago lo sea también físicamente, etc.

6.5.5. LA FISCALIDAD DEL DESCUENTO

Se ha de considerar también en el descuento de efectos otro coste que encarece este medio de financiación, que es el coste fiscal, por aplicación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y cuyo origen no está en el propio descuento sino en el documento mismo. En él se regula la obligación de tributar entre otros a:

- a) Las letras de cambio.
- b) Los pagarés cambiarios emitidos a la orden o los nominativos cuando estos con posterioridad se endosen o descuenten en una entidad bancaria.
- c) Los cheques a la orden o que sean objeto de endoso siempre que no sean para su cobro en el banco librado.
- d) Los documentos expedidos en el tráfico mercantil que, por sí mismos, acrediten, literalmente y con carácter autónomo, el derecho económico de su legítimo tenedor para cobrar de la persona que designen y en el lugar y fecha, que, con independencia de los de emisión, el propio documento señale, una cantidad determinada de dinero o signo que lo represente (recibos).

ESCALA DE TRIBUTACIÓN DE LOS EFECTOS TRIMBRADOS			
Hasta 24,04 8,41	0,06	De 1.502,54 a 3.005,06	
De 24,05 a 48,08 16,83	0,12	De 3.005,07 a 6.010,12	
De 48,09 a 90,15 33,66	0,24	De 6.010,13 a 12.020,24	
De 90,16 a 180,30 67,31	0,48	De 12.020,25 a 24.040,48	
De 180,31 a 360,61 134,63	0,96	De 24.040,49 a 40.080,97	
De 360,62 a 751,27 269,25	1,98	De 40.080,97 a 96.161,94	
De 751,28 a 1.502,53 538,51	4,21	De 96.161,95 a 192.323,87	

Por lo que exceda de 192.323,87 euros a 0,018030 euros por cada 6,01 euros o fracción que se liquidará siempre en metálico.

Esta obligación se hace extensiva a cualquier soporte utilizado para la representación del documento, queriendo el texto legal incluir implícitamente el descuento de recibos mediante soporte informático, que es la forma habitual en que grandes, medianas y pequeñas empresas están utilizando para girar los documentos de cobro, suponiendo un ahorro por el coste la manipulación del papel supone tanto para la empresa como para la entidad financiera.

7. EL CONTRATO *FACTORING*

7.1. CONCEPTO Y FINALIDAD ECONÓMICA

El *factoring* es una operación que consiste en la cesión en firme -antes de su vencimiento- de un crédito comercial a corto plazo, por su titular a una firma especializada, denominada sociedad factor, quien asume el riesgo de insolvencia y se encarga de su contabilización y cobro, percibiendo a cambio una comisión. La sociedad factor soporta el 100 por 100 de clientes fallidos, al tiempo que realiza gestiones de cobro. Ofrece sus servicios sobre todo a la pequeña y mediana empresa, convirtiendo sus ventas a corto plazo en ventas al contado, puesto que la transmisión se hace, generalmente, "sin recurso". El *factoring* convierte activos exigibles en activos disponibles; la sociedad factor no presta dinero, sino que compra deudas a corto plazo.

7.2. TIPOLOGÍA DE *FACTORING*

El *factoring* puede ofrecerse bajo diversas modalidades:

- a) **Factorizando total o parcialmente** la cartera de clientes, de modo que sólo se ceden los créditos contra uno o varios clientes o bien todos los créditos.
- b) **Con recurso o sin recurso.** Dado el coste que supone asegurar el cobro de la cartera de clientes, el empresario puede optar por realizar las cesiones con recurso, es decir, asumiendo él el riesgo de insolvencia de sus clientes.
- c) **Con financiación o sin financiación.** El empresario puede utilizar sólo al factor como un servicio de administración en la gestión de cobro de su facturación abonando el importe cobrado cuando dichos cobros se produzcan, sin que exista ninguna financiación.

7.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA SOCIEDAD DE <i>FACTORING</i>	
- o Garantía de cobro 100 por 100. - o Control y cobro de las facturas, con todos los gastos inherentes. - o Investigación de clientes. - o Control de riesgos.	

- o Financiación de las facturas o créditos. mediante anticipo de su importe antes del vencimiento.

El factor como contraprestación a sus servicios recibe una comisión, consistente en un porcentaje sobre el valor de los créditos cedidos para su cobro. Cuando además se presten servicios financieros se cobra un porcentaje sobre las cantidades anticipadas.

En cualquier caso, la operación supone un coste, en cuanto a la comisión y los intereses.

- a) La **comisión** suele oscilar entre el 1% y el 3% del volumen de los negocios efectuados y depende básicamente del volumen total de facturación, del valor medio de las facturas, del plazo de vencimiento y de la diversificación del riesgo transferido.
- b) El **interés**, respecto a la financiación de los créditos comerciales, suelen ser de alrededor de un 1% superiores a los aplicados por el descuento en el sistema bancario y siempre calculados sobre la parte financiada.

VENTAJAS

- O Ahorro de tiempo, gastos y precisión en la obtención de informes.
- O Permite la máxima movilización de la cartera de deudores y garantiza el cobro de todos ellos.
- O Puede ser utilizado como una fuente de financiación y obtención de recursos circulantes.
- O Permite recibir anticipos de los créditos concedidos.

DESVENTAJAS

- o Coste elevado. El tipo de interés aplicado es mayor que el descuento comercial convencional.
- o El cliente queda sujeto al criterio de la sociedad factor para evaluar el riesgo de los distintos compradores.

7.4. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FACTOR Y DE LA EMPRESA

Son obligaciones básicas de la sociedad factor **cobrar las deudas** con corrección comercial, **respetar las fechas de vencimiento** de las facturas para proceder al cobro y asumir el riesgo de insolvencia. La empresa, sin embargo deberá ceder todos los créditos que originen sus ventas, notificar a la clientela la firma del contrato con la sociedad factor, facilitar al factor los informes y los pagos recibidos directamente de la clientela, obligándose a ceder los fondos así obtenidos, retribuir a la sociedad factor por los servicios prestados, no intervenir en la gestión de cobro salvo que la sociedad factor lo solicite y responder del incumplimiento de las obligaciones contraídas con sus clientes.

8. LOS AVALES BANCARIOS

8.1. CONCEPTO

A veces el Banco no presta dinero, sino que presta su firma al cliente, cosa que le permite a éste obtener dinero de otro Banco o concertar operaciones o contratos en los cuales la otra parte exija de un Banco garantice el cumplimiento del contrato o las posibles responsabilidades de su cliente. Como una más de las operaciones de activo que tradicionalmente efectúan los Bancos, se encuentra la prestación de esta fianza o avales por cuenta de sus clientes, por quienes salen fiadores; consecuencia indudable de la credibilidad que el Banco tiene en las instituciones financieras y su solvencia.

En virtud de ello podemos definir por aval o fianza el **contrato por el cual se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste**. Los términos fianza y aval son expresiones que, no significando sustancialmente lo mismo, se utilizan indistintamente.

En lo referente a la relación Banco-cliente, el afianzamiento nacerá siempre de una relación contractual que además será de carácter oneroso y mercantil; todo ello, sin perjuicio de que la exigencia de la fianza a nuestro cliente pueda provenir de un simple pacto con el tercero acreedor, o bien impuesta por ley o por vía judicial.

La relación entre el banco y el acreedor se establece mediante el documento mercantil denominado aval, cuyo texto generalmente viene impuesto por el acreedor e incluso por regulación legal.

El aval suscrito por el banco es entregado al deudor, que es quien lo solicita, y que a su vez lo hará llegar a su acreedor sin necesidad de que éste estampe en él su firma en prueba de conformidad y debe ser registrado por el Banco en un Registro Especial de Avaluos, debiendo consignar en el documento el número de registro de dicho aval.

PARTES QUE INTERVIENEN EN LA EMISIÓN DE UN AVAL BANCARIO

- a) **El banco:** quien en este supuesto actúa como fiador o avalista.

- b) **El cliente:** que será el afianzado, avalado o deudor pero que podrá ser, a su vez, el deudor obligado principal u otra persona.
- c) **El acreedor o beneficiario:** es aquél ante quién se presta la fianza o aval beneficiario de la misma y, por, lo tanto, ante quién la entidad de crédito asume la responsabilidad (que tiene contraída su cliente).

8.2. TIPOLOGÍA DE AVALES

Los avales, según la finalidad por la que se requieren pueden clasificarse según las siguientes modalidades.

a) Avales económicos: Son aquellos avales prestados por las entidades bancarias a favor de sus clientes y ante sus proveedores con la finalidad de garantizar el pago de estos en el suministro normal de mercancías, de manera que sus proveedores tienen la garantía de que en el supuesto de que sus clientes no cumplan sus obligaciones de pago sobre las facturas de material entregado podrán reclamarle al banco su cobro, hasta donde el límite del aval garantice.

b) Avales financieros: Son aquellos avales prestados por las entidades bancarias garantizando el pago de una deuda concreta con un vencimiento determinado que tenga su cliente frente a su acreedor. Este puede ser prestado en un documento individual, en una letra de cambio, en un pagaré, en un contrato de préstamo, etc.

c) Avales técnicos: Son aquellos avales que el banco presta a los clientes de su cliente garantizando las responsabilidades derivadas del buen funcionamiento de los trabajos realizados por este, o del buen funcionamiento de los bienes vendidos. Este tipo de aval se diferencia de los dos anteriores en que el banco no está garantizando una obligación económica de su cliente, sino las responsabilidades dimanantes del buen hacer de su cliente en su actividad económica.

d) Los pre-avales: El pre-aval es aquel documento que suscribe el banco con el cliente, cuando este no solicita un aval, sino el compromiso de avalarle ante su acreedor, bien porque las relaciones jurídicas existentes entre ambos aún no han

desembocado en unas determinadas obligaciones, o bien porque el acreedor se conforma con el simple compromiso de avalar por parte del Banco. El pre-aval precisa también de toma de razón en el registro especial del banco.

8.3. EL COSTE ECONÓMICO DE LOS AVALES

El contrato que la empresa solicitante del aval suscribe con una entidad de crédito o de emisión de avales (SGR) tienen por regla general dos tipos de comisiones:

- a) **Comisión de formalización:** Esta comisión se cobra a los clientes por parte de los bancos en el momento de la emisión del aval y suele oscilar entre un 0,25% y un 0,50%. Compensa los gastos de redacción y registro del documento de aval.
- b) **Comisión por riesgo:** Esta comisión se cobra por parte de la entidad avalista de forma trimestral y compensa el riesgo asumido por la misma. Suele tener cobro por trimestres naturales y se devenga mientras no se devuelva el documento original del aval o éste haya vencido de pleno derecho, así como su plazo de exigibilidad.

8.4. LA CONTRAGARANTÍA

Entre las distintas operaciones que los bancos realizan, resultan frecuentes las de prestar, a favor de determinadas personas u organismos, garantías o avales que garanticen ante los mismos el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por parte de sus clientes. En estos casos, ha de regularse, por un lado, la relación contractual del banco con el acreedor, es decir, con la persona o entidad beneficiaria del afianzamiento o aval, y de otra parte, la relación del banco con el afianzado o deudor, tendente a la cobertura del riesgo que implica la garantía que se presta. A esta cobertura se le denomina contragarantía.

Para todo aval (o pre-aval) que el banco vaya a prestar, deberá formalizarse, previa o simultáneamente, la correspondiente póliza de contragarantía o relevación de fianza, que será intervenida por fedatario público.

Debe tenerse en cuenta que la entidad ha de cubrirse, simultáneamente, del riesgo que implica la obligación contraída por los avales o afianzamientos que presta y para ello, habrá de suscribirse el documento en el que, correlativamente, el afianzado garantice al banco las obligaciones de pago contraídas. Estas garantías constituidas a favor del banco pueden ser de

naturaleza personal o prendaria, y pudiendo prestarse por los propios afianzados o por éstos y terceras personas, debiendo hacerse constar siempre en forma escrita.

8.5. EL VENCIMIENTO DE LOS AVALES

Los avales tienen en general un vencimiento determinado y que suele coincidir con el vencimiento de la obligación principal existente entre el cliente y su acreedor, aunque cuando estos avales han de prestarse ante la Administración Pública es frecuente que estos deban emitirse con carácter indefinido. En la operativa bancaria, para considerar cancelado cualquier aval, bastará con que el cliente acredite de forma clara y terminante el cumplimiento de la obligación garantizada. Generalmente, la verificación por el cliente de tal hecho se hará mediante la devolución del documento original del aval. Es frecuente incluir también en los avales un plazo máximo de exigibilidad que suele ser de unos 15 o 30 días posteriores al vencimiento del aval, momento a partir del cual si no se ha realizado reclamación alguna por parte del beneficiario se entendería vencido definitivamente.

9. EL CONTRATO DE CONFIRMING

Las grandes y medianas empresas suelen tener un importante control sobre sus pagos a proveedores, sobre todo cuando estos son numerosos y se tienen que administrar los pagos de numerosas facturas. En la mayoría de las ocasiones estas facturas son pagadas a un plazo de vencimiento que puede oscilar entre los 30 y los 90 días según los casos.

Para con la finalidad de facilitar la gestión del pago de una empresa a sus proveedores, y que estos puedan anticipar si lo desean y sin recurso³ los importes pendientes de cobro mediante una factorización de las facturas pendientes, las entidades financieras ponen a disposición de estas grandes y medianas empresas los contratos de confirming.

9.1. CONCEPTO

El *confirming* puede definirse como aquella operación financiera consistente en confirmar por parte de una entidad financiera a un vendedor que asume el pago de una operación de compraventa por cuenta de su cliente de las facturas que se le relacionan en pago de bienes vendidos o servicios prestados.

Se trata por tanto de una forma de garantizar el pago de las compras de bienes o servicios a los proveedores de una empresa, teniendo una finalidad similar a los contratos de avales vistos en el apartado anterior, con la diferencia de que mientras el contrato de aval se presta la garantía ante un único beneficiario, mediante el confirming esta garantía de pago se realiza a una pluralidad de proveedores, y queda condicionado a que éstos, anticipen de la entidad financiera comunicadora el importe de la factura comunicada.

Los proveedores podrán, por tanto, desde el momento en que reciban la comunicación de la confirmación de pago anticipar los importes notificados con un descuento financiero, eludiendo así el riesgo de insolvencia futura de su cliente.

9.2. FUNCIONAMIENTO

Para poder realizar confirmación de facturas es requisito necesario que previamente la empresa pagadora tenga contratada una línea de confirming con una entidad financiera que disponga de este producto financiero en su catálogo de productos de inversión. Cuando la empresa da la orden de pago

³ La compra de créditos sin recurso supone que la compra del crédito por parte de un acreedor a otro se realiza sin la cláusula “salvo buen fin”, es decir, que asume la posible insolvencia del deudor en que pudiera incurrir antes del vencimiento y pago del crédito.

de sus facturas a la entidad financiera, sus proveedores ya están en disposición de solicitar los anticipos de las mismas, si así lo desean. De esta manera, el proveedor obtiene liquidez inmediata.

El proveedor puede pactar con la entidad financiera que le ha comunicado la confirmación de pagos las siguientes opciones:

- Cesión global (automática): Pactada esta opción, todos los créditos actuales (y futuros) comunicados por el cliente del proveedor se anticipan automáticamente.
- Cesiones puntuales: Si se pactan cesiones puntuales la empresa podrá elegir anticipar de su cliente solo determinadas facturas, de entre todas las enviadas.
- Si decide no anticipar el pago, deberá esperar al vencimiento de las facturas cedidas por su cliente. En este caso la entidad financiera actuará como un mero gestor de pago mediante cheque o transferencia.

Esta modalidad de pago es **muy frecuente en el sector de las promociones inmobiliarias** financiadas con créditos al promotor por parte de la entidad financieras. De este modo, los pagos estipulados en los contratos entre la promotora inmobiliaria y los diferentes industriales que intervienen en la construcción son gestionados en su totalidad por la entidad de crédito financiadora que, a su vez, cuando se ordenan los pagos futuros de las facturas ofrece a este colectivo de industriales la posibilidad de anticipar su cobro sin recurso.

9.3. VENTAJAS DEL CONFIRMING

La utilización de este producto financiero tiene ventajas tanto para la empresa pagadora de facturas como para sus proveedores.

9.3.1. VENTAJAS PARA LA EMPRESA PAGADORA

La empresa pagadora tiene dos ventajas importantes concertando este producto financiero:

- 1) la **descarga administrativa** que comporta este sistema, toda vez que la entidad financiera se encarga de procesar la información recibida, circularizando a los proveedores las órdenes de pago y encargándose a su vencimiento de la ejecución física de las mismas.

- 2) Al ofrecer a sus proveedores ventajas incuestionables, la empresa pagadora puede negociar con ellos **condiciones de mejor ventaja**, tales como aplazamiento en el periodo medio de pago, precios, etc.

9.3.2. VENTAJAS PARA LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA PAGADORA

Esta fórmula de cobro de sus clientes por parte de una empresa tiene numerosas ventajas, especialmente cuando se trata de empresas de pequeño tamaño con dificultades de acceso a la financiación bancaria:

- 1.- **Anticipo del 100%** sobre importe de las ventas realizadas a la empresa pagadora.
- 2.- **Cobertura de riesgo hasta el 100%** (eliminando cualquier otro aseguramiento de crédito)
- 3.- Condiciones financieras a tipos preferenciales de mercado.
- 4.- Al no existir documento negociable se evita el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (TIMBRE), con el consiguiente ahorro de aproximadamente el 0,4% en cada giro.
- 5.- La tratarse por parte de la entidad financiera como una compra en firme y sin recurso del crédito contra su cliente esta financiación no tiene peso en el pasivo de su balance y no consume riesgo bancario.

10. LAS GARANTÍAS COMO MEDIO DE OBTENER FACILIDADES CREDITICIAS

10.1. LA NECESIDAD DE APORTAR GARANTÍAS

No cabe duda de que la razón fundamental por la cual una entidad de crédito (o cualquier acreedor) presta dinero a una persona (física o jurídica) es la confianza de que ésta se lo devolverá en las condiciones pactadas sin la necesidad de recurrir a la protección de los tribunales de justicia para recuperar el dinero prestado. Pero, a pesar de esta confianza, puede suceder que el deudor no devuelva el dinero prestado por varias circunstancias:

- a) Porque nunca hubiera tenido la intención de hacerlo, habiendo engañado a la entidad de crédito en las circunstancias que motivaron su concesión y en su compromiso de devolverlo. En este supuesto estaríamos ante un delito de **estafa**, tipificado en el Código Penal.
- b) Porque sus circunstancias económicas y sus expectativas han cambiado desde que se solicitó el crédito/préstamo y en algún momento de la fase de devolución de la deuda no disponga de dinero para hacerlo. En esta situación puede existir una doble solución, bien refinanciar la deuda acomodando las nuevas condiciones de vencimientos e importes a una situación más cómoda con el deudor para cumplir, o bien dirigiéndose contra su patrimonio para, a través de un procedimiento judicial, proceder a la venta pública de sus bienes como medio de recuperar el dinero prestado. Para poder hacer efectiva esta segunda opción será necesario que el deudor, o quien haya garantizado la deuda con él tenga bienes para ello, lo cual hace necesario valorar estos aspectos en el momento de estudiar la viabilidad de la concesión de la facilidad crediticia al deudor.

Es, por tanto, la posibilidad futura de incumplimiento del deudor de sus obligaciones de reembolso del crédito en los plazos pactados en los contratos lo que faculta a la entidad de crédito a valerse de las garantías aportadas para poder cobrar la deuda. Es por ello, que la solvencia del deudor sea un segundo elemento para valorar minuciosamente en el momento de la concesión de un crédito. La solvencia del deudor supone entonces la garantía de la entidad de crédito.

Podemos definir, por tanto, como garantía aquel derecho que, para asegurar el cumplimiento de una obligación, otorgan a su titular un poder sobre el patrimonio del deudor o garante, bien en su totalidad, bien un bien concreto, que le permite, si aquel no cumple, cobrar la deuda con el producto de su enajenación.

10.2. TIPOLOGÍA DE GARANTÍAS

10.2.1. SEGÚN QUIEN LA PRESTA

10.2.1.1. PRESTADA POR EL DEUDOR

Según el Código Civil, del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. Por tanto, el deudor, al margen de las garantías adicionales que se presten siempre será responsable de que el acreedor recupere lo que le prestó, junto con los intereses y comisiones que se proveyeran en el contrato. Si existiera más de un prestatario en un mismo préstamo por haberse otorgado a más de una persona, todos ellos tendrán el deber solidario -porque así se establece generalmente en los contratos bancarios- de cumplir con las obligaciones dimanantes del contrato, de modo que de no reembolsarse al banco el importe del préstamo éste puede dirigirse contra cualquiera de los deudores y reclamarle la totalidad de la deuda, pudiendo después, el prestatario que pagare su totalidad al banco, repetir contra el resto la parte que le corresponda a cada uno.

10.2.1.2. PRESTADA POR TERCEROS

Si a criterio del Banco la solvencia acreditada por el futuro prestatario no le parece suficiente, éste deberá encontrar alguna persona (física o jurídica) que se obligue solidariamente con él en el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato, sin ser por ello prestatario, El carácter solidario de la responsabilidad se establece sistemáticamente en los contratos bancarios, dado que el código civil, prevé la responsabilidad subsidiaria de los fiadores o garantes de las deudas de los obligados principales o garantizados.

10.2.2. SEGÚN EL CONTENIDO DE LA GARANTÍA

TIPOLOGIA TRADICIONAL DE GARANTIAS		
PERSONAL	REAL	ATÍPICAS
Prestada por el deudor La fianza prestada por terceros	Hipoteca inmobiliaria Hipoteca mobiliaria Prenda con desplazamiento	La Carta de Patrocinio

	Prenda sin desplazamiento	
--	---------------------------	--

10.3. LAS GARANTÍAS PERSONALES: LA FIANZA

10.3.1. CONCEPTO

Son aquellas formas de garantía en las que la solvencia personal y patrimonial de terceras personas viene a reforzar la propia solvencia del cliente para responder de las deudas contraídas con el Banco en el supuesto de que éste no las hiciera efectivas a su vencimiento.

10.3.2. MODALIDADES DE FIANZA

10.3.2.1. FIANZA PRESTADA EN OPERACIÓN DETERMINADA

En este caso la fianza se presta para una deuda determinada y en un contrato determinado, limitándose, por tanto, la fianza, exclusivamente a esta operación y por el tiempo que dure la misma. Una vez ha vencido la operación satisfactoriamente, los fiadores quedan libres de cualquier obligación frente al banco, aunque tengan los garantizados otras deudas frente a él, si en ellas no han prestado fianza.

MODELO DE CLÁUSULA DE FIANZA EN UN CONTRATO BANCARIO

CLÁUSULA XXX. - Asimismo, D. _____ y D. _____ con domicilio en _____ y con domicilio en _____. como garantes, se obligan solidariamente, entre sí y con los acreditados, en los mismos términos, condiciones y responsabilidades que se establecen en este contrato, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, y dejando especialmente afectos al buen fin del mismo, todos sus bienes presentes y futuros.

10.3.2.2. FIANZA PRESTADA SOBRE UN LIMITE DE RIESGO

En este supuesto el fiador o fiadores firman un documento independiente, denominado póliza de afianzamiento de modo que éstos se comprometen solidariamente junto al garantizado y frente al banco en todas las deudas que tenga el garantizado en ese momento frente al banco o aquellas otras nuevas deudas que este contraiga, hasta un límite pactado y durante un

plazo pactado, que normalmente es prorrogable salvo denuncia de una de las partes. Este tipo de garantía es frecuente que sea prestada por los socios frente a las obligaciones de la sociedad.

10.4. LAS GARANTÍAS REALES

Por garantía real se comprenden todas aquellas garantías en las que determinados bienes quedan afectos al cumplimiento de una obligación. Cuando esta garantía recae sobre bienes inmuebles se denomina hipoteca, en caso contrario se denomina prenda.

Es normalmente el propio prestatario o acreditado el sujeto que suele aportar un bien o derecho en garantía de su obligación, aunque también puede realizarlo un tercero, persona física o jurídica.

10.4.1. LA HIPOTECA

10.4.1.1. CONCEPTO

La hipoteca es un derecho real de garantía que permite a su titular pedir, en caso de que el deudor no cumpla voluntariamente su obligación, la venta en pública subasta del bien hipotecado (generalmente un inmueble) y destinar el precio obtenido al pago de la deuda. En las operaciones de financiación bancaria es muy extendido como medio de garantía en operaciones de elevada cuantía y largos plazos.

10.4.1.2. CARACTERÍSTICAS

Entre sus características más importantes podemos destacar las siguientes:

- a) Las hipotecas que realizan los bancos son en su práctica totalidad realizadas sobre bienes inmuebles y quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y a sus normas de desarrollo⁴. Estas normas contienen un régimen específico de protección de las personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes de préstamos (consumidores o no) que estén garantizados mediante hipoteca sobre bienes

⁴ Las normas de desarrollo de la Ley 5/2009 han sido el Real Decreto 309/2019 de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas en materia financiera y la Orden ECE/482/2019 de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010 de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea la adquisición de derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos por construir.

b) Salvo que se formalice como medio de conseguir mayores garantías ante un riesgo ya existente, los bancos no admiten una hipoteca sobre un inmueble que se encontrara ya hipotecado, embargado, con alguna cláusula que pudiera afectar a la resolución del contrato de compraventa, etc.

c) La hipoteca puede establecerse como garantía de un préstamo o crédito concreto a formalizar o bien para cubrir los riesgos existentes con el Banco, hasta un importe determinado -hipoteca de máximo-.

d) El bien hipotecado puede pertenecer a un sujeto distinto del prestatario.

e) Si no está alquilado se establece la prohibición de hacerlo sin el consentimiento previo del banco.

f) Cuando el prestatario es una persona física es conveniente que comparezca el consorte, bien en la misma calidad o como garante personal o manifestando meramente la conformidad a la misma.

g) Con respecto a la subrogación de préstamos hipotecarios será de aplicación la Ley 2/94 de 30 de marzo sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

10.4.1.3. FORMALIZACIÓN

Las hipotecas deben formalizarse en **escritura pública** ante notario, bien en anexo especial al contrato de otorgamiento de crédito o bien como un contrato independiente si la deuda que se pretende garantizar ya existe. Una vez suscrita se ha de inscribir en el Registro de la Propiedad.

En la escritura se debe detallar el bien a hipotecar y dejar de manifiesto la no existencia de cargas -en su caso- indicándose un domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos. Si se hipotecaran varias fincas afectas a un mismo crédito, se deberá establecer la responsabilidad por la que responderá cada una de ellas. También debe determinarse el valor que sirva de tipo en la subasta. Este valor será el de tasación o, si este es inferior, el

correspondiente a la suma del principal, intereses durante al menos 24 meses al tipo de interés de demora pactado en la escritura, las comisiones, y costas.

10.4.1.4. BIENES HIPOTECABLES

No todos los bienes pueden ser hipotecables. La legislación establece que bienes pueden ser objeto de hipoteca, entre los que podemos relacionar los siguientes:

- a) Los bienes inmuebles susceptibles de inscripción (viviendas, locales, naves industriales, terrenos rústicos, etc....), aunque ya estuvieran hipotecados.
- b) Los derechos reales enajenables.
- c) El derecho de usufructo.
- d) La nuda propiedad
- e) Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros semejantes de naturaleza real.
- f) Las concesiones administrativas,
- g) El derecho de retracto convencional

La Ley prohíbe hipotecar las servidumbres, los usufructos legales -excepto el concedido al cónyuge viudo por el código civil- y el uso y la habitación.

No cabe duda de que todos los bienes susceptibles según el código civil de ser hipotecados no son de interés a las entidades de crédito como medio de garantizar sus operaciones de riesgo. Podríamos afirmar que sólo las primeras hipotecas sobre bienes inmuebles son de exclusivo interés como medio de garantía sobre un préstamo o crédito a conceder. A pesar de ello, cuando un préstamo o crédito ha vencido y el deudor no lo puede satisfacer será cuando las entidades de crédito estarán dispuestas a renegociar la deuda vigente con la aportación de nuevas garantías, pudiendo entrar en juego el resto de las referidas, pero esto sólo sucederá cuando el banco no encuentre bienes de fácil realización en el patrimonio del deudor o garantes personales para recobrar su deuda a través de un procedimiento ejecutivo en el que poder embargar bienes para ello.

La constitución una garantía real sobre un determinado bien no limita la responsabilidad del deudor al bien pignorado o hipotecado si no puede devolver la deuda, sino que es costumbre bancaria incorporar en todos los contratos de pignoración o hipotecarios la garantía personal adicional del deudor con todos sus bienes presentes y futuros.

10.4.1.5. MODALIDADES DE GARANTÍAS HIPOTECARIAS

Existen diversas modalidades de garantía hipotecaria en función de las características de formalización de la misma:

a) **La hipoteca inmobiliaria:** Es aquella que se constituye sobre un bien inmueble y por un importe que cubra inicialmente el importe que el banco hace entrega al cliente y se constituye simultáneamente a la entrega del dinero por parte de la entidad de crédito a su cliente.

b) **La hipoteca de máximo:** Es aquella hipoteca que se suele formalizar para cubrir bajo esta forma de garantía los riesgos que la entidad de crédito asuma con el acreditado desde ese momento, pudiendo incluir los riesgos vivos de existir en el momento de la constitución- y los que pudieran constituirse en el futuro, hasta un plazo determinado, no respondiendo el bien inmueble más que del límite de capital definido en la escritura. Esta modalidad hipotecaria se utiliza cuando se constituye sobre una apertura de crédito.

c) **La hipoteca de superposición de garantía:** Es aquella hipoteca inmobiliaria que se constituye ante la dificultad por parte del deudor de poder satisfacer sus créditos al banco, señalando en la escritura las deudas vencidas o en curso que quedarán garantizadas.

10.4.1.6. LA HIPOTECA MOBILIARIA

La hipoteca mobiliaria, regulada en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento, de 16 de diciembre de 1954 sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre los que se impone, cualquier que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida.

Esta modalidad hipotecaria se reserva para operaciones atípicas dentro del negocio bancario, pero no por ello carentes de existencia, teniendo el nexo común de que sobre bienes objeto de hipoteca existe algún tipo de registro administrativo que controla los cambios de titularidad:

BIENES OBJETO DE HIPOTECA MOBILIARIA

a) Establecimientos mercantiles: Debe el titular del crédito también ser titular o arrendatario del local con facultad de traspasar.

b) Vehículos a motor: automóviles, camiones, autocares, tractores, autobuses, motocicletas y cualquier otros susceptibles de matrícula en la Dirección General de Tráfico.

c) Las aeronaves.

d) La maquinaria industrial: máquinas, instrumentos o utensilios instalados y destinados por su propietario a la explotación de una industria y cine, directamente concurren a satisfacer las necesidades de la explotación de la misma.

e) La propiedad intelectual e industrial: siempre que estén inscritas en los registros correspondientes.

Este tipo de hipotecas, como ya se ha venido adelantando, sólo son de interés para las entidades de crédito cuando no existan otras de mejor realización y no se confíe en el recobro judicial de la deuda mediante el procedimiento ejecutivo.

10.4.2. LA PRENDA

10.4.2.1. CONCEPTO

La prenda, según el Código Civil es un derecho real de garantía que, para asegurar el cumplimiento de una obligación, otorga a su titular la posesión de una cosa mueble, propiedad del pignorante o de un tercero, a fin de que, si se incumple la obligación, pueda vender la cosa pignorado satisfaciendo la deuda con el importe obtenido.

Ha de tenerse en cuenta las disposiciones que sobre la prenda puedan existir en otras legislaciones forales, como sucede en Cataluña, con la *Lley 19/2002 de 5 de juliol de Drets Reals de Garantia*, que tienen un contenido similar al establecido por el Código Civil.

10.4.2.2. CARACTERÍSTICAS

a) Es una garantía accesoria a una obligación principal, que es la deuda que mantiene el deudor con la entidad de crédito.

b) El pignorante debe tener plena capacidad y el poder de disposición de la cosa objeto de la prenda en calidad de propietario.

- c) El pignorante sigue siendo el dueño de la cosa, con todos sus derechos salvo la posesión.
- d) Puede garantizar cualquier tipo de obligaciones (préstamos, crédito, descuento, avales)
- e) El acreedor tiene preferencia a cobrar su crédito reteniendo la cosa pignorada a proceder ante Notario la venta de la cosa en subasta pública.

10.4.2.3. FORMALIZACIÓN

Se debe formalizar mediante anexo o cláusula especial en el contrato en el cual se crea la obligación garantizada, detallándose sucintamente los bienes pignorados. El contrato deberá estar formalizarse ante un notario, con las siguientes particularidades:

- a) **en la prenda de acciones:** éstas deben estar depositadas en la entidad bancaria, debiendo el pignorante notificar a la entidad emisora de los mismos dicha circunstancia.
- b) **en la prenda de letras de cambio o pagarés:** se pignorarán mediante endoso, incluyéndose la cláusula valor en prenda.
- c) **en la prenda de derechos:** Si son nacidos de cuentas a plazo o Libretas de ahorro, el contrato establece normalmente la posibilidad del Banco de apropiarse de los mismos en el supuesto de no cumplirse la obligación garantizada.

10.4.2.4. MODALIDADES DE PRENDA

10.4.2.4.1. LA PRENDA CON DESPLAZAMIENTO

La prenda con desplazamiento es aquella en la que el acreedor pignorante pasa a tomar posesión del bien pignorado, que deberá tratarse necesariamente de un bien mueble susceptible de posesión.

BIENES PIGNORABLES CON DESPLAZAMIENTO

- Valores (acciones, obligaciones, deuda pública, fondos de inversión)
- Letras de cambio y/o pagarés
- Imposiciones a plazo y/o libretas de ahorro
- Saldos de anotaciones en cuenta (Valores por el sistema de anotaciones en cuenta).

Estas son las modalidades de prenda más deseadas por la banca, sobre todo las imposiciones a plazo fijo o sobre valores bursátiles, en los demás supuestos la entidad de crédito tendrá también presente la solvencia del librado en el título a pignorar.

No cabe duda de que puede ser objeto de prenda con desplazamiento cualquier bien mueble susceptible de posesión, pero lógicamente los anteriormente enunciados son aquellos que pueden ser de interés a las entidades de crédito por su fácil realización, no siendo de su interés, vehículos, joyas u otros objetos, salvo que constituyan un medio de garantía adicional a una deuda ya contraída.

10.4.2.4.2. LA PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

Al amparo de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento, de 16 de diciembre, de 1954, sólo puede ser objeto de prenda sin desplazamiento los bienes enajenables, debiéndose constituir bajo escritura pública e inscrita en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, a cargo de los Registradores de la Propiedad, no pudiendo desde el momento de su inscripción el deudor vender los bienes dados en prenda sin el consentimiento del acreedor.

No cabe duda de que la falta de posesión del bien pignorado por la entidad de crédito no otorga a ésta una sólida garantía, por lo cual sólo se acude a estas modalidades como medio de mejorar garantías ante posibles situaciones de refinanciación de deudas ya existentes.

BIENES PIGNORABLES SIN DESPLAZAMIENTO

- Los frutos y cosechas pendientes.
- Los animales, así como sus crías y productos.
- Las máquinas y aperos de las explotaciones
- Las mercancías y materias primas almacenadas, objetos de valor artístico e histórico.

10.5. LAS GARANTÍAS ATÍPICAS. LAS DENOMINADAS CARTAS DE COMFORT, CARTAS DE PATROCINIO O COMFORT LETTER

10.5.1. CONCEPTO

En las empresas pertenecientes a grupos empresariales importantes y de reconocida solvencia no es habitual que sus sociedades matrices avalen o afiancen sus operaciones bancarias, sino que tan sólo facilitan carta de conformidad o conocimiento de las relaciones bancarias con su filial, comprometiéndose, en mayor o menor medida a apoyarla suficientemente, y que ha venido denominándose tradicionalmente en términos jurídicos como cartas de patrocinio o de *comfort*.

Estas cartas, no son más que una manifestación de intenciones por parte de la sociedad matriz, con la finalidad de facilitar a su sociedad filial la obtención de facilidades crediticias, cuyo alcance puede ser muy variado, como veremos más adelante.

10.5.2. FINALIDAD ECONÓMICA

Las razones de la existencia de las cartas de confort no son gratuitas, sino que, siguiendo a Aramendía las podríamos justificar en las siguientes:

1. No contabilización en el pasivo del balance de la matriz.
2. Dificultades para la obtención de una garantía formal, considerando que en la Ley de Sociedades Anónimas, esta facultad sólo puede ser utilizada por la Junta de Accionistas, de modo que no sería, en absoluto, operativo para sociedades de gran dimensión, con una gran diversificación de su accionariado, a veces incluso, enormemente atomizado -sociedades que cotizan en bolsa, que deberían constituirse en Junta de accionistas para facultar a los Administradores a emitir dicho aval.
3. Posibilidad de eludir, de este modo, las pertinentes autorizaciones administrativas, en el supuesto de cartas emitidas por matrices extranjeras, que de otro modo estarían sometidas a las normas del control de cambios.
4. Mantener un prestigio sobre la seriedad en la gestión de sus filiales que eximen a la banca de la solicitud de

una garantía formal como condición para trabajar con ellas.

5. La posibilidad de no obligarse jurídicamente sino sólo, en el ámbito más cómodo y difuso de las obligaciones morales.

10.5.3. MODALIDADES

Las cartas de confort se han venido clasificando en dos grupos: débiles y duras. La razón para clasificarse en una u otra modalidad dependía en gran medida del grado de compromiso que asumía la sociedad emisora de la carta en su texto, debido al gran número de cláusulas que se pueden incorporar. Seguidamente se relacionan alguna de las cláusulas típicas de este tipo de garantías sin intención de limitar sus posibilidades:

CLÁUSULAS DECLARATIVAS:

- a) Reconocimiento de la concesión de un crédito a una sociedad filial, expresando su conformidad al mismo.
- b) Reconocimiento de que ha sido decisivo para su concesión, la obtención de la carta de confort.
- c) Declaración del porcentaje de capital que ostenta sobre su filial.
- d) Declaración de que es política del grupo que las sociedades filiales respeten escrupulosamente sus compromisos financieros.

CLÁUSULAS RELATIVAS AL MANTENIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIAL.

- a) Asunción del compromiso de conservar la participación en la sociedad filial, en tanto el crédito no haya sido reembolsado en su totalidad.
- b) Compromiso de no vender la participación sin la aprobación explícita del Banco.
- c) Compromiso de no vender la participación sin aportar unas garantías que el Banco considerara suficientes.

CLÁUSULAS RELATIVAS AL CONTROL DE LA FILIAL

Manifestación de intervenir en la gestión de la sociedad mientras mantenga el control efectivo de la sociedad.

CLÁUSULAS REFERENTES AL APOYO FINANCIERO

- a) Compromiso de tomar medidas para asegurar que su filial cumpla efectivamente con sus obligaciones y compromisos financieros con un determinado Banco.
- b) Compromiso de dotar a su filial con los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones financieras si ésta no fuera capaz de hacerlos frente con sus propios recursos.

c) Manifestación de ocuparse por todos los medios de que la sociedad financiera pueda llevar a cabo los compromisos adquiridos.

d) Compromiso de hacer frente a las responsabilidades contraídas por la filial en el supuesto de que ésta no pueda hacer frente.

Esta relación es tan sólo una muestra del distinto tipo de declaraciones, compromisos y manifestaciones que se pueden insertar en una declaración de patrocinio, en función del grado de responsabilidad que la sociedad matriz desee adquirir frente al Banco acreedor de la filial. En algunas de ellas se darán simples declaraciones -confort débil- mientras que en otras se pueden asumir compromisos más directos -confort duras-.

10.5.4. EFICACIA JURÍDICA

Las cartas de confort no suponen una garantía tipificada por nuestra legislación, ni prácticamente por ninguna legislación europea. No por ello debe de obviarse un profundo estudio sobre las mismas, considerando su importante proliferación que, en un origen venían a otorgarse por sociedades matrices pertenecientes a otros estados pero que, actualmente es también común su expedición por sociedades matrices nacionales.

La fuerza jurídica de las Cartas de *Comfort* varía según el contenido de las mismas. Según la tradición jurisprudencias de nuestro país en el derecho de obligaciones, nos induciría a asegurar que las cartas que contengan meras declaraciones o políticas de actuación no tendrían ninguna fuerza ante los tribunales, limitándose a ser meros compromisos morales cuyo alcance no pasará del descrédito comercial ante las entidades financieras de todo el mundo que podrían perder la confianza en sus compromisos de apoyo, siendo ello quizás, un perjuicio de mayor magnitud. A pesar de ello, las declaraciones que incluyen manifestaciones falsas sí que podrían acabar generando obligaciones en base al quebranto del principio de la buena fe. En el supuesto de cartas con compromisos más concretos de apoyo financiero, aportación de garantías, etc. considero que sí podría generar responsabilidades concretas para la sociedad emisora de la carta, y así ha tenido el reconocimiento jurisprudencial explícito en la Sentencia del Tribunal Supremo español de fecha 13 de febrero de 2007.

MODELO DE CARTA DE CONFORT

BANCO DEL VALLES
08006 BARCELONA

Madrid, 1 de julio de 2000

Muy señores nuestros

Tenemos conocimiento de la concesión, por BANCO DEL VALLES de las facilidades crediticias que se detallan, a las filiales de nuestra compañía CONSTRUCCIONES ESPONTANEAS, S.A.

La operación conjunta asciende a un montante de QUINIENTOS MILLONES DE PESETAS, instrumentada en tres pólizas de crédito con vencimiento final en julio de 2001 y con cláusula de reconducción tácita anual. Los prestatarios e importes asignados son los siguientes, todos ellos participados al 100% por CONSTRUCCIONES ESPONTANEAS, S.A.

Miniconstrucciones, S.A. 1.500.000 de euros

Maxiconstrucciones, S.A. 1.750.000 de euros

Por la presente, y en referencia a dichas facilidades, les confirmamos que CONSTRUCCIONES ESPONTANEAS, S.A. posee la mayoría del capital social de Miniconstrucciones, S.A. y Maxiconstrucciones, S.A., controlando su gestión y que, al mismo tiempo, es nuestra política asegurar que nuestras filiales están administradas de tal manera que puedan hacer frente a las obligaciones contraídas con terceros.

Por ello les manifestamos que, en el caso CONSTRUCCIONES ESPONTANEAS tuviera la intención de disminuir su participación en el capital social de Miniconstrucciones, S.A. o Maxiconstrucciones S.A., perdiendo la mayoría, nos comprometemos a informarles previamente y, en su caso, a negociar con Uds. posibles soluciones que permitan asegurar el cumplimiento de las facilidades crediticias concedidas.

Atentamente,

CONSTRUCCIONES ESPONTANEAS S.A.

Por poder;

10.6. LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son un tipo de establecimientos financieros de crédito, y por tanto entidades sujetas a la disciplina del Banco de España, que aparecieron para dar respuesta específica a la problemática de las pymes para acceder a la financiación ajena.

Están reguladas por la Ley 1/1994 de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca.

Se caracterizan por ser **sociedades de capital variable**, dedicadas a conceder garantías por aval con la finalidad de facilitar o abaratar la financiación de sus socios, fundamentalmente pymes, en el tráfico bancario, emitiendo avales totales o parciales a favor de entidades financieras cuando conceden créditos o préstamos a sus beneficiarios. Por sólo pueden actuar en el sistema financiero emitiendo avales. Esta función también podrían realizarla los bancos, dado que entre sus actividades está la de poder emitir avales, pero como ya hemos visto el tipo de avales que emiten los bancos está más limitada a la tipología de avales vistos anteriormente, y rara vez se emiten en favor de otras entidades financieras, función que sí que asumen como propia las SGR, o el ICO como veremos seguidamente.

Estas entidades **financian su actividad mediante la emisión de obligaciones** por un importe inferior al 100% de sus recursos propios y al menos 4/5 partes de sus socios deberán ser pymes, pudiendo tener socios protectores, los cuales proporcionan solvencia y posibilitan la concesión e avales, que normalmente son entidades financieras.

Para poder prestar avales a los bancos, las sociedades de garantía recíproca deberán tener previamente aprobadas por diferentes entidades financieras **líneas de garantía**, para aceptar sus avales, hasta un importe determinado, consumido el cual ya no aceptarían más avales de esta SGR hasta que se hubieran cancelado de anteriores.

10.6.1. FUNCIONES

Entre sus funciones principales cabe destacar las siguientes:

- a) **Conceder avales** (nunca créditos o préstamos) a las pymes para permitirles su acceso a la financiación bancaria.
- b) Facilitar el acceso de las empresas avaladas a líneas de financiación privilegiada y obtener **mejores**

- condiciones** de financiación de los conseguidos por sí solas en el mercado.
- c) Proporcionar **servicios de información** que den a la pyme instrumentos financieros mejor adaptados a sus necesidades.
 - d) Facilitar a los empresarios un asesoramiento eficaz en cuanto que analizan, evalúan y aconsejan sobre el proyecto de inversión que la pequeña empresa va a realizar.

Para poder asegurar sus funciones, y en garantía de sus acreedores por los riesgos asumidos estas entidades están obligadas a mantener como mínimo el 75% de sus recursos propios invertidos en deuda pública o renta fija negociada en mercados secundarios oficiales, no pudiendo destinar más de un 25% de su activo a inversiones en inmovilizados materiales o participaciones financieras.

10.6.2. FUNCIONAMIENTO

Las empresas que necesitan un nivel de financiación para alguna operación de inversión concreta y que supera el importe máximo que la entidad financiera accedería a financiar puede acudir a estas sociedades de garantía recíproca, con la que el banco tenga concedido un límite de garantía aún no consumido, para solicitar un aval bancario por el importe restante para que el banco le facilite el 100% del importe necesitado. De este modo el banco financia el 100% pero un porcentaje determinado (normalmente entre un 20% y un 50%) será avalado por estas sociedades de garantía recíproca.

Entre estas sociedades podemos destacar **CESGAR, AVALIS, GARANTIA, EXTRAVAL, AFIGAL**, hasta un total de 18 entidades inscritas en el registro del Banco de España.

Estas entidades para contragarantizar el aval emitido, es decir, para obtener una cobertura y garantía suficiente a los riesgos contraídos solicitan también garantías a sus beneficiarios igual que los solicitaría una entidad financiera, que podría consistir en garantías personales o reales.

Estas SGR, para minimizar el riesgo asumido y facilitar una disminución del coste del aval para sus socios, pueden constituirse en sociedades de **reafiancamento**⁵ cuyo objeto social comprende el reaval de las operaciones de garantía otorgadas por las SGR.

⁵ En España sólo existe una institución de refianzamiento subsidiario denominada CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.), cuyo capital es un 97,5% del Estado a través del ICO y el resto está participado por otras entidades financieras como BBVA, CECA, Crédito y Caución, y el 1,2% por otras SGR.

10.7. LA GARANTÍA DEL ESTADO EN LAS LINEAS DE FINANCIACIÓN ICO COVID

A raíz del parón obligado en la actividad económicas de la mayoría de las empresas que fueron consideradas no esenciales al inicio de la pandemia provocada por la Covid'19, se hizo necesario poder facilitar el acceso al crédito de forma generalizada a todas las empresas que, durante un período de tiempo indeterminado en su momento que les iba a impedir facturar y generar ingresos durante ese período de tiempo, mientras que sus obligaciones de pago seguirían vigentes. Las medidas laborales a través de la concesión de ERTE's posibilitó que las empresas pudieran suspender los contratos de trabajo con sus empleados y enviarlos a casa, y que estos pudieran seguir cobrando la mayoría de su salario durante ese período, pero el cumplimiento de las obligaciones de pago de deudas con proveedores, administraciones, entidades financieras seguían estando vigentes y la imposibilidad de continuar vendiendo podía provocar una cadena de impagos que habría acabado en una crisis financiera y económica sin precedentes, que sólo las empresas con mayor músculo financiero podrían haber soportado.

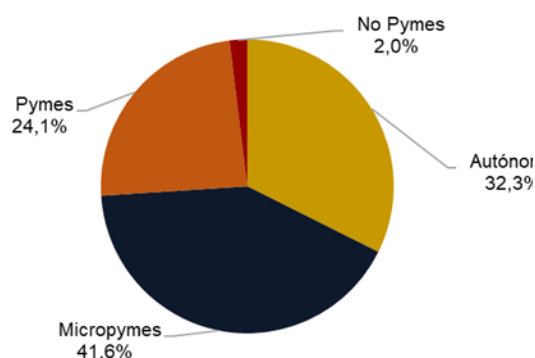
Las entidades de crédito difícilmente podrían haber facilitado crédito al sector empresarial en una situación con tanta incertidumbre, dado que la prima de riesgo de todo el sector empresarial se disparó con la llegada de la pandemia y las entidades habrían cortado el flujo de liquidez para evitar sus futuras insolvencias por la imposibilidad de que las empresas pudieran devolver los créditos en un futuro.

Ante esta situación el Estado tuvo que reaccionar para que las empresas no quedaran colapsadas financieramente, impulsando el crédito a las pymes por parte de las entidades de crédito con un aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que garantizaba hasta desde el 60% hasta el 80% de los créditos recibidos en función del tamaño de la pyme o la finalidad de los mismos. Con esta finalidad se aprobó el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo que en su artículo 29 aprobó una Línea de Avaless del Estado de hasta 100.000 millones de euros, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que en enero de 2021 ya había sido con sumida en un 88%. La ley daba una vigencia de esta línea hasta el 1 de diciembre de 2021.

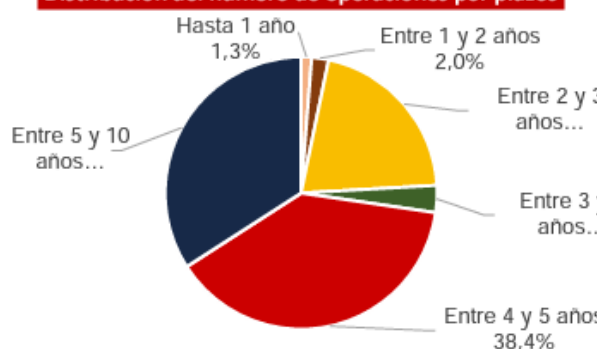
A través de esta línea de avales las pymes y los autónomos han podido acceder a créditos y a préstamos con carencia de capital con el aval del ICO y con la finalidad de atender pagos de salarios, de proveedores, de alquileres, suministros, necesidades de circulante y otras necesidades de pagos como cuotas de préstamos, deudas con la administración, vencimientos de

créditos bancarios, etc. Para ello la ley exigía el cumplimiento de una serie de requisitos como que no se utilizaran para refinanciar deudas preexistentes con entidades de crédito, o que fueran empresas calificadas como morosas en el sistema bancario y otros límites de importe en función de una serie de indicadores económicos de la empresa.

Distribución del número de operaciones por tipo de empresa



Distribución del número de operaciones por plazos



Resumen Avaes solicitados			
	Autónomos y Pymes	No Pymes	Total Línea
Operaciones (número)	1.000.447	20.128	1.020.575
Aval Solicitado (Millones €)	68.281,0	24.599,3	92.880,3
Financiación (Millones €)	85.444,1	36.933,9	122.377,9

Fuente: ICO. Informe seguimiento Líneas de Avaes junio 2022.

El sector de la cultura, el ocio y el turismo ha sido el mayor demandante de estas líneas de financiación, seguido de la construcción y las infraestructuras, como puede observarse en el siguiente extracto de los datos obtenidos del informe del ICO:

DISTRIBUCIÓN DE AVALES LIQUIDEZ SOLICITADOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD				
Sector	Nº ops.	Nº empresas	Aval solicitado (millones €)	Financiación (millones €)
Turismo, Ocio y Cultura	185.601	130.159	13.719,5	18.436,3
Construcción e Infraestructuras	109.834	67.568	10.058,6	13.170,3
Servicios Empresariales, Profesionales y Administrativos	92.813	65.499	8.222,5	11.059,2
Bienes de Consumo y Retail	84.886	59.621	4.984,4	6.397,7
Distribución Comercial de Alimentos y Bebidas	68.008	42.002	7.096,0	9.432,2
Bienes de Equipo e Industriales	67.291	37.980	7.761,6	10.051,9
Agricultura, Ganadería y Pesca	58.160	39.961	4.332,7	5.545,4
Transporte y Logística	51.678	29.997	3.820,2	4.900,3
Automoción y Material de Transporte	48.324	27.485	5.344,9	7.069,2
Industria Textil Y Moda y Retail	47.696	29.809	3.752,8	4.880,6

Fuente: ICO. Informe seguimiento Líneas de Avaes junio 2022

En la actualidad estas líneas están ya vencidas y no es posible acogerse a ellas, aunque la vigencia de los préstamos y créditos concedidos permanecerán aún muchos años en los balances de las empresas españolas. El ICO ha facilitado la ampliación de los vencimientos de estas líneas a las empresas que lo necesiten que pasará a 8 años de los 5 iniciales.

10.8. LOS COVENANTS⁶.

10.8.1. CONCEPTO

Se ha decidido finalizar el apartado de las garantías bancarias con un tipo de garantía diferente de las vistas hasta ahora, que no supone en sí la aportación de mayor garantía patrimonial a la operación en caso de impago, pero sí el cumplimiento de una serie de indicadores en sus finanzas, o de compromisos de hacer o no hacer algo, que tengan por finalidad una actuación financiera prudente de la empresa que asegure la capacidad de pago futura de los créditos o préstamos recibidos y su solvencia financiera. Estos *covenants* se instrumentan como cláusulas en los contratos financieros, habitualmente con grandes empresas, donde se comprometen las actuaciones fijadas por parte del prestatario

⁶ La palabra “covenants” es un anglicismo que equivale a cláusulas de compromiso en un contrato financiero.

10.8.2. TIPOS DE COVENANTS

Las entidades de crédito pueden imponer diferentes tipos de *covenants* que se pueden agrupar en tres tipos:

Covenants positivos (de hacer): Por ellos se obligan a las empresas a llevar a cabo algunas acciones. Entre ellos se encontrarían todos aquellos que tienen por finalidad asegurar el flujo de caja como, por ejemplo: la compra de una sociedad, el mantenimiento del equipo directivo, una ampliación de capital o el mantenimiento de licencias de explotación de una marca, por ejemplo. También es muy habitual aquellos que obligan a la empresa a facilitar de forma periódica determinada documentación económica o financiera de la empresa (cuentas anuales, informes de auditoría, o estados financieros mensuales). Este último tipo de *covenants* es muy frecuente tanto en el caso de grandes empresas como de pymes y autónomos.

Covenants negativos (de no hacer): Contrario al caso anterior, estos *covenants* impiden a la empresa llevar a cabo ciertas acciones, como no contraer endeudamiento nuevo hasta no vender determinados activos no esenciales, o comprar otras empresas.

Covenants financieros: son muy extendidos y tienen que ver con cumplir ciertos parámetros financieros de balance o cuenta de resultados encaminados a preservar la rentabilidad, la solvencia, el endeudamiento o la liquidez. Entre este tipo de *covenants* estaría el mantener un determinado nivel de EBITDA sobre los intereses a pagar (*Interest coverage ratio*), o de fondo de maniobra (*current ratio*), o que relaciona el total de la deuda financiera con el patrimonio efectivo (*leverage ratio*), entre muchos otros.

10.8.3. EFICACIA JURÍDICA DE LOS COVENANTS

Como todo incumplimiento del clausulado de un contrato, las consecuencias serán las que se hayan previsto en el propio contrato, por lo que normalmente, en los contratos financieros se establece que el incumplimiento de los *covenants* por parte del prestatario otorga a la entidad de crédito el derecho a resolver el contrato de forma anticipada y a exigir la devolución total del importe adeudado hasta ese momento.

En la práctica **no se suelen ejecutar estas cláusulas de forma inmediata**, sino que tras un proceso de negociación con la empresa se busca, bien una reestructuración de la deuda que garantice el cobro de la misma por parte de

la entidad de crédito en el caso de que no se esté cumpliendo determinados *covenants* financieros, o bien eximir del cumplimiento de alguno de ellos, también denominado *whiver*. Si no es posible un acuerdo sí será posible entonces que la entidad de crédito dé por vencido la facilidad crediticia otorgada y exija judicialmente su devolución.

11. LA REESTRUCTURACIÓN Y REFINANCIACIÓN DE LAS DEUDAS EMPRESARIALES Y ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO EN SITUACIONES DE DIFICULTAD

11.1. REESTRUCTURACIÓN VS. REFINANCIACIÓN

En muchas ocasiones ambos términos se utilizan de forma similar, o de forma indiferente, cuando en realidad cada concepto tiene un significado diferente:

- a) **Refinanciación:** Supone la firma de un nuevo contrato de financiación a menudo en mejores condiciones que las anteriores, o bien agrupando deudas en un único pago, pero sin que ello suponga una incapacidad de hacer frente a las deudas actuales. No se obtendrían mayores plazos con este proceso, sino mejores condiciones financieras en el mismo plazo.
- b) **Reestructuración:** La reestructuración refleja sin embargo una incapacidad de pago de los créditos actuales, por lo que se requiere un alargamiento de los plazos para poder atender a sus pagos, y en ocasiones incluso añadiendo una quita de parte de la deuda para hacerlo posible. En este proceso se encarece el tipo de interés en numerosos casos, aunque si es de aplicación los Códigos de Buenas Prácticas a los que se han adherido muchas entidades de crédito, asumen con ello el compromiso de no encarecer la financiación en los procesos de reestructura de la deuda.

11.2. LAS CALIFICACIONES CONTABLES DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS

Las situaciones en dificultad comienzan a advertirse por las entidades de crédito una vez se ha producido el primer impago de una deuda a su vencimiento. A partir de ahí las entidades intentarán resolver el impago antes de que transcurran los primeros 30 días de impago, momento en que la deuda vencida pasa a tener una situación contable diferente (denominada **subestándar**) y obliga a las entidades a provisionar por ello con dotaciones mayores. Transcurridos 90 días desde el primer vencimiento las entidades están obligadas a contabilizar la deuda como (**dudoso contable**) y a provisionar fuertes cantidades de dinero por las deudas pendientes de cobro.

Cualquier proceso de reestructuración llevado a cabo por una entidad de crédito con una empresa conlleva automáticamente la calificación crediticia

d subestándar a calificar así también todos los créditos que la empresa tenga con la entidad de crédito y a realizar dotaciones por provisiones más significativas, que perdurarán hasta que la empresa lleve un tiempo significativo pagando con normalidad (12 meses). Una vez una empresa pasa de tener una calificación crediticia de estándar a subestándar o dudoso contable cierra ya toda posibilidad a nuevas financiaciones con esta entidad crediticia. Si la calificación es de dudoso contable, el bloqueo ya es con todo el sistema bancario, dado que esta información se hace visible para el resto de las entidades a través de la información transmitida a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) ya vista en los apuntes de la Clase 1.

11.3. LA LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Ante los primeros síntomas de dificultades financieras las entidades de crédito podrían tener la tentación de reducir las facilidades crediticias otorgadas a las empresas por ejemplo no renovando límites de crédito de financiación de circulante que vencen, para intentar evitar la recalificación crediticia a futuro de los créditos. No obstante, a través de la [ley 5/2015 de fomento de la actividad empresarial](#), se impone a las entidades de crédito la obligación de comunicar con una antelación mínima de tres meses cualquier deseo de reducción del flujo de financiación a una empresa (pyme o microempresa) que supere el 35%, bien sea por no renovación de los límites de crédito, bien sea por reducción.

Para el cálculo del flujo de información la ley solo obliga a tener en consideración el conjunto de contratos de crédito bajo la forma de apertura de crédito, descuento comercial, anticipo, pago aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros que cumplan con una función equivalente de financiación otorgados a una pyme por una misma entidad de crédito.

Dentro de los diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la voluntad de reducción del flujo crediticio, preavisado con una antelación mínima de tres meses, la entidad de crédito debe proporcionar gratuitamente a la pyme un documento denominado «**Información Financiera-PYME**» basado en toda la información que hubiere recabado de ella en relación con su flujo de financiación. La información se asentará en los datos históricos a disposición de la entidad de crédito.

No obstante, y al margen de la situación descrita anteriormente para los supuestos de terminación o disminución del flujo de financiación, las pymes tienen asimismo el derecho a solicitar la Información Financiera-PYME en cualquier momento y de forma incondicionada, la cual se le debe de facilitar

en un plazo máximo de 15 días y previo pago del coste que la Entidad de crédito tenga fijado para este servicio.

12. LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS BANCARIOS: LAS PÓLIZAS Y LAS ESCRITURAS PÚBLICAS.

12.1. FUNCIÓN DE LAS PÓLIZAS

Las pólizas son un documento privado justificativo de un contrato mercantil y firmado por las partes que tiene por finalidad demostrar la existencia del mismo. Por ello la póliza, para ser conceptuada como tal, no requiere que sea intervenida por notario, aunque circunstancia aparte será que sin esta intervención carecerá de eficacia ejecutiva. Cada vez es más frecuente que con la finalidad de agilizar los procedimientos de financiación las entidades de crédito están recurriendo a la formalización de pólizas no intervenidas por notarios siempre que no existan garantes en la operación o no superen determinados importes.

12.2. EL ALCANCE JURÍDICO DE LAS PÓLIZAS INTERVENIDAS POR NOTARIOS

La ley otorga a las pólizas bancarias intervenidas por notarios -al igual que cualquier otra escritura pública- unos efectos diferentes que a otros contratos mercantiles celebrados entre empresarios:

1. El notario da fe del otorgamiento de la póliza y la fecha y lugar de la firma.
2. El notario crea una presunción de veracidad de lo declarado por los otorgantes en la póliza (identidad/capacidad de los firmantes, denominación del acto o contrato, etc.).

Las declaraciones de voluntad incorporadas en la póliza prevalecen en el tráfico jurídico y vinculan a los tribunales en tanto no sea destruida por otros medios probatorios, de modo que la carga de la prueba de que dichas declaraciones son nulas, falsas o simuladas deberá probarlas quien las alega (presunción iuris tantum). Es importante señalar que la eficacia probatoria de la póliza se agota en su ámbito competencial, negándose esta eficacia fuera de su competencia, bien por razón de la materia o de territorio.

12.3. LA RECLAMACIÓN JUDICIAL DE LAS PÓLIZAS

12.3.1. EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

Las pólizas intervenidas por Notario son documentos ejecutivos y por ello las deudas no pagadas por los clientes de los bancos amparadas en estas pólizas pueden ser reclamadas ante los Tribunales de Justicia a través de procedimientos judiciales sumarios "ejecutivos" que pretenden una rápida realización de los bienes del deudor para el cobro del acreedor de la deuda reclamada mediante el embargo y posterior subasta judicial de los bienes del deudor.

12.3.2. EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL MONITORIO

El procedimiento monitorio es una vía de reclamación ante la jurisdicción civil de cantidades (sin límite de importe) más rápida y ágil, cuando no se dispone de un título ejecutivo. Se utiliza por las entidades de crédito para exigir el pago de deudas líquidas, determinadas, vencidas y exigibles.

Este procedimiento se inicia mediante solicitud en el juzgado a través de una demanda, que no requiere de intervención ni de abogado ni de procurador si la deuda no supera los 2.000€, en la cual el solicitante debe demostrar que existe una deuda líquida, determinada, vencida y exigible. Para ello se puede utilizar facturas, recibos, albaranes o cualquier otro tipo de documentos que sirvan para acreditar una deuda. Una vez el juez admite la solicitud se requiere al deudor para que realice el correspondiente pago, aunque también puede oponerse a esa demanda. En ese caso el procedimiento derivará hacia un procedimiento declarativo que seguidamente veremos.

En el caso de que el deudor ni pague ni se oponga a la demanda el juez despacha ejecución de la deuda reclamada como si de un título ejecutivo (póliza intervenida) se tratara.

Esta es la vía por la que las entidades de crédito reclaman todas aquellas deudas que no estén sustentadas en una póliza intervenida o en una escritura pública.

12.3.3. EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DECLARATIVO

La vía más costosa de reclamación judicial para las entidades de crédito es el procedimiento judicial declarativo, que requiere de una demanda en la que se tendrá que probar la existencia del crédito debido y los impagos, además de que el deudor podrá argumentar todo cuanto estime conveniente en defensa de su situación. Tras un largo proceso judicial el procedimiento

terminará con una sentencia, que en el caso de ser favorable a la entidad de crédito se convertirá en el título ejecutivo a partir del cual podrá iniciar la fase de reclamación forzosa. Un título de igual eficacia que el que permite una póliza bancaria intervenida por un notario.

También se deberá derivarse a un procedimiento declarativo en el momento en que tras iniciarse un procedimiento judicial monitorio el deudor no esté de acuerdo con la reclamación.